

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Para: Isabel Madariaga Cuneo **Fecha:** 30/09/2020

De: Catalina Fernández Carter e Ilan Sandberg Wiener

CC: Iván Fuenzalida Suárez

Asunto: Análisis del artículo 10 de la Ley 21.154

I. INTRODUCCIÓN

1. Esta minuta tiene por objeto determinar el alcance del artículo 10 de la Ley 21.154 que “Designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”, que dispone:

“Artículo 10.- Excepción de denuncia. En el desarrollo de sus visitas preventivas y con el propósito de resguardar los fines del Comité de Prevención contra la Tortura, los expertos y su personal de apoyo no estarán obligados a denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, los expertos y el personal de apoyo deberán denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad o sean víctimas de algunos de los actos definidos como tortura en la letra a) del artículo 2, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos para el ejercicio de la atribución contemplada en el número 5 del artículo 3 de la ley N° 20.405. En la comunicación efectuada con motivo de una denuncia, prevalecerá la reserva de la información, en los términos dispuestos en el artículo siguiente, y la prohibición de hacer públicos datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada”.

2. En particular, el objetivo de este análisis es determinar: (1) el alcance del término “*riesgo vital*” y la forma de su determinación, a efectos de dar lugar a la obligación de denuncia de los miembros del Comité de Prevención contra la Tortura (el “Comité”); (2) la aplicación de dicha disposición a casos en que el autor del acto de tortura no sea un funcionario público; (3) la relevancia que tendría el consentimiento de la víctima y las consecuencias que podría tener que ésta se niegue a que se realice la denuncia por miedo a represalias, especialmente teniendo en cuenta el deber de reserva previsto en la parte final del artículo 10 y en el artículo 11 de la Ley 21.154.
3. A efectos de determinar el alcance de la referida disposición, esta minuta examina el artículo en su contexto, hace referencia a la discusión desarrollada en el proceso legislativo (la “Historia de la Ley”) y menciona otras disposiciones legales similares que puedan ser

aplicables. Lo anterior, en cumplimiento de las normas de interpretación de la ley previstas en los artículos 19 a 24 del Código Civil, y que incluyen referencia al examen de su historia fidedigna (artículo 19); el contexto de la disposición (artículo 22, párrafo primero) y el uso de otras leyes para ilustrar el alcance de una ley (artículo 22, párrafo segundo).

4. Asimismo, este análisis también incluye referencia a estándares internacionales que puedan ser útiles en la interpretación de la Ley 21.154, lo que también encuentra asidero en las referidas normas de interpretación de la ley. Así, en primer lugar, el artículo 21 del Código Civil indica que *“las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte”*. A este respecto, no puede ignorarse que la Ley 21.154 fue adoptada en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por Chile, en particular por medio de la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En ese sentido, mucho de los términos previstos en la Ley 21.154 son términos del arte en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, y pueden ser interpretados en conformidad con los estándares internacionales en la materia. Ello queda por lo demás confirmado por la regla supletoria prevista en el artículo 24 del Código Civil que dispone que, no pudiendo tener aplicabilidad los criterios anteriores, *“se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”*. En efecto, el espíritu general de la legislación es indiscutidamente dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales, que deben ser examinadas en el proceso interpretativo.

II. SOBRE LOS HECHOS QUE REVISTEN “RIESGO VITAL”

5. La regla general sobre la obligación de denuncia se encuentra prevista en el artículo 175(b) del Código Procesal Penal, que impone a todo empleado público la obligación de denunciar los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La misma regla se encuentra prevista en el artículo 61(k) de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que igualmente incluye dentro de las obligaciones de cada funcionario público el denunciar ante el Ministerio Público o la policía los crímenes o simple delitos.
6. Sin embargo, como ya se adelantaba, el artículo 10 de la Ley 21.154 establece una excepción a dicha regla general, disponiendo que los expertos y el personal de apoyo del Comité no estarán obligados a denunciar los crímenes y simples delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, al mismo tiempo, el artículo 10 establece una contra excepción, según la cual los expertos y el personal de apoyo deberán denunciar aquellos hechos que revistan *“riesgo vital”* para las personas privadas de libertad o sean víctimas de algunos de los actos definidos como tortura. Sin embargo, el artículo no precisa la forma de determinación de dicha contra excepción, a fin de establecer su ámbito de aplicación.

A. Historia de la Ley

7. La regla prevista en el artículo 10 de la Ley 21.154 y en particular, la excepción (y contra excepción) de denuncia aplicable a los miembros del Comité ya venía incluida en el Mensaje Presidencial presentado por la Presidenta Michelle Bachelet el 19 de mayo de 2017. Si bien el Mensaje mismo parecía dar cuenta de que la denuncia en casos de riesgo vital era

facultativa (disponiéndose que los miembros del Comité “*podrán denunciar a las autoridades correspondientes*” en casos que puedan suponer un riesgo vital para las personas privadas de libertad)¹, lo cierto es que el artículo contenido en el Proyecto de Ley presentado –entonces, el artículo 11– disponía una obligación (y una excepción) de denuncia en los siguientes términos:

“Artículo 11.- Excepción de denuncia. En el desarrollo de sus visitas preventivas y con el propósito de resguardar los fines del Comité, los expertos y expertas y el personal de apoyo del mismo no estarán obligados a denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

*Sin embargo, los expertos y expertas y el personal de apoyo deberán denunciar aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad. En la comunicación con motivo de una denuncia, prevalecerá la reserva de la información, en los términos dispuestos en el artículo siguiente, y la prohibición de hacer públicos datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada”.*² [Énfasis agregado]

8. Al respecto, el Mensaje Presidencial indicaba que el espíritu de esta excepción era “*reflejar la vocación de diálogo que deben tener las entidades nacionales de prevención contra la tortura*”.³ Asimismo, éste indicaba que el trabajo de los expertos y expertas de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura se basa “*en el diálogo más que en la denuncia*”,⁴ idea que fue repetida varias veces durante el trámite legislativo.⁵
9. En primer término, el Proyecto de Ley fue examinado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En tal oportunidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos se refirió a esta excepción al deber de denuncia, señalando que ella existe con el

¹ Historia de la Ley, Mensaje, p. 6. Énfasis agregado. Cabe señalar que para efectos de la presente minuta, las referencias a la Historia de la Ley corresponden a la versión en formato Word, que puede descargarse del siguiente sitio: <https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7658/>. Los números de página de la versión PDF son diversos.

² *Ibid*, p. 11.

³ *Ibid*, p. 6.

⁴ *Ibid*, p. 4. Esta misma idea fue señalada también por la Subsecretaría de Derechos Humanos, señora Lorena Frías, en el marco de su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien señaló: “*Es importante tener en consideración que los MNPT no son un órgano de denuncia, sino que se basan en el establecimiento de un diálogo con las autoridades a cargo de los lugares de privación de libertad*”. Historia de la Ley, Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, p. 27.

⁵ Por ejemplo, cuando el Proyecto de Ley estaba siendo revisado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos volvió a retirar que los mecanismos “*no son un órgano de denuncia, sino que se basan en el establecimiento de diálogos y recomendaciones, siendo considerados como ‘magistraturas de convencimiento’*”. Ver: Historia de la Ley, Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, p. 68. De igual manera, en la Discusión en Sala en la Cámara de Diputados, el diputado señor Poblete, en representación de la Comisión de Derechos Humanos informó sobre el proyecto de ley, donde se volvió a reiterar la idea de que este mecanismo basa el éxito de su trabajo “*en el diálogo más que en la denuncia*”. Ver Historia de la Ley, Discusión en Sala, Cámara de Diputados, p. 80. A su vez, el Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado también vuelve a reiterar esta idea de que el Mecanismo está más basado en el diálogo que en la denuncia. Ver: Historia de la Ley, Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pp. 107 y 109. A su vez, en la Discusión en Sala en el Senado, el senador Insulza volvió a reiterar que “*este mecanismo no es un órgano de denuncia; busca establecer un diálogo con las autoridades*”. Ver Historia de la Ley, Discusión en Sala, Senado, p. 139.

- fin de asegurar el desempeño del Comité.⁶ En un sentido similar, la Directora de la Oficina Regional para América Latina de la Asociación de Prevención contra la Tortura (APT) también hizo referencia a esta disposición, señalando que, si bien comprendía el espíritu de la norma, era de la opinión de que “*un MNP debería alejarse de la práctica de la denuncia, puesto que es precisamente un mecanismo de prevención*”, indicando que a su juicio esta norma generará complicaciones para su implementación.⁷ De igual manera, el Director Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que en su opinión, si un órgano que tiene a su cargo el sistema de prevención tiene además la tarea de litigar, no tendrá el mismo grado de confianza y aceptación que si tuviera esa prohibición expresa.⁸
10. Sin embargo, otros de los invitados se manifestaron contrarios a dicha excepción. Por ejemplo, el Director Ejecutivo del Observatorio Social Penitenciario señaló que no estaría de acuerdo con la excepción de denuncia, indicando que ella sería contraria a la norma del artículo 175 del Código Procesal Penal.⁹ De igual manera, el Coordinador del Observatorio para el cierre de las Escuelas de las Américas (SOA Watch) indicó que en casos de “*situación graves [sic] de tortura*”, los expertos debían informar reservadamente al Ministerio Público, y que por ello debería excluirse la “*excepción de denuncia*” del entonces artículo 11 del Proyecto de Ley.¹⁰ El mismo también sostuvo que los miembros del Mecanismo deberían hacer la denuncia de manera reservada en casos en que exista evidencia de personas sometidas a torturas o tratos degradantes.¹¹
 11. En esta misma línea, el diputado René Saffirio presentó una indicación para suprimir el citado artículo 11, preguntándose cuál sería el objetivo de crear un organismo de prevención de la tortura que no pueda denunciarla, y señalando además que ella sería contradictoria con la norma general que rige respecto de los funcionarios públicos, y que iría contra la naturaleza del sistema, al menos desde el punto de vista público.¹²
 12. En cambio, el diputado Jaime Bellolio indicó que la excepción de denuncia se justificaba por el hecho de que una persona que acude a un recinto penitenciario puede tomar conocimiento de otro tipo de delitos (como la posesión de teléfonos celulares o drogas),¹³ aunque aclaró más adelante que los miembros del Comité “*deberán denunciar aquellos hechos que revistan riesgo vital*”, indicando que “*aparece obvio que cuando hay torturas ello implica riesgo vital*”.¹⁴ En un sentido similar, el diputado Tucapel Jiménez señaló que lo que se buscaba

⁶ Historia de la Ley, Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, p. 28.

⁷ *Ibid*, p. 31.

⁸ *Ibid*, p. 36.

⁹ *Ibid*, p. 33.

¹⁰ *Ibid*, pp. 37-38.

¹¹ *Ibid*, p. 39.

¹² *Ibid*, p. 42.

¹³ *Ibid*, p. 43.

¹⁴ *Ibid*, p. 43.

- prevenir es la ocurrencia de torturas, y una forma de hacerlo es por medio de las denuncias de ese crimen, pero no de otros delitos.¹⁵
13. Por su parte, el Jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos también hizo referencia a esta disposición, indicando: “[e]sta norma se justifica en el hecho que este organismo tiene una especial naturaleza, que es ser esencialmente de colaboración y persuasión”, señalando que entenderlo como un organismo de denuncia no generaría las confianzas con las personas que administran lugares de privación de libertad.¹⁶ Ahora bien y al mismo tiempo, éste también señaló que “*existen hechos de tal envergadura que siempre queda a salvo el actuar frente a ciertos órganos, habilitados legalmente para que se les entregue información y formalizar la respectiva denuncia, por ejemplo el INDH o el Ministerio Público*”.¹⁷
 14. Más adelante, el diputado Bellolio sugirió modificar la redacción del artículo en cuestión, indicando que la obligación de denuncia debía limitarse a aquellos hechos que tengan que ver con tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, casos en los cuáles existiría esta denuncia obligatoria.¹⁸ El diputado René Saffirio manifestó estar de acuerdo con dicha propuesta,¹⁹ y también lo hizo el representante del Ejecutivo, que propuso agregar también la obligación de denunciar respecto de delitos contra la vida.²⁰
 15. Por ello, una vez sometida a votación la indicación original de los diputados René Saffirio, Tucapel Jiménez y Felipe Letelier de suprimir dicho artículo 11, ella fue rechazada por unanimidad, incluyendo el voto en contra de sus patrocinantes.²¹ En cambio, una segunda indicación presentada por los diputados René Saffirio, Roberto Poblete, Tucapel Jiménez, Jaime Bellolio, Felipe Letelier, Jorge Sabag, Sergio Ojeda y Raúl Saldívar que propuso agregar a continuación de la frase “*sin embargo, los expertos y expertas y el personal de apoyo deberán denunciar aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad*” la siguiente “*o sean víctimas de algunos de los actos definidos como tortura en la letra a) del artículo 2*”, fue aprobada por unanimidad.²²
 16. El proyecto luego fue discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y luego en Sala, siendo aprobado sin que existieran otras modificaciones a este artículo.
 17. En Segundo Trámite Constitucional, el Proyecto fue discutido en general por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En tal oportunidad, la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos sostuvo que “*de conformidad con la ley, es el Instituto es el que tiene la capacidad de denunciar y querellarse por diversos delitos, incluyendo los de tortura*”,²³ señalando en

¹⁵ *Ibid*, p. 43.

¹⁶ *Ibid*, p. 44.

¹⁷ *Ibid*, p. 44.

¹⁸ *Ibid*, p. 44.

¹⁹ *Ibid*, p. 44. Ver también p. 46.

²⁰ *Ibid*, pp. 44-45.

²¹ *Ibid*, p. 51.

²² *Ibid*, p. 51.

²³ Historia de la Ley, Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, p. 116.

consecuencia que “*en los casos del inciso segundo de la norma debe ser el Instituto y no el Comité, quien denuncie y deduzca querellas por los delitos que revisten riesgo vital para las personas privadas de libertad*”.²⁴

18. Más adelante en el proceso legislativo, el Presidente de la República presentó una indicación al proyecto de ley, proponiendo primero agregar en el párrafo segundo del artículo, a continuación de la frase “*deberán denunciar*”, la frase “*ante el Ministerio Público o bien poner los antecedentes en conocimiento del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos*”.²⁵ Asimismo, el Presidente presentó una segunda indicación que proponía reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

*“Sin embargo, los expertos y el personal de apoyo deberán denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad o sean víctimas de algunos de los actos definidos como tortura en la letra a) del artículo 2, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos para el ejercicio de la atribución contemplada en el artículo 3 N° 5 de la ley N° 20.405. En la comunicación con motivo de una denuncia, prevalecerá la reserva de la información, en los términos dispuestos en el artículo siguiente, y la prohibición de hacer públicos datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada”.*²⁶

19. La propuesta del Ejecutivo de reemplazar el segundo párrafo del artículo fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Derechos Humanos del Senado.²⁷ Sin embargo, en dicha oportunidad, el senador Navarro expresó su reparo respecto del artículo 11, indicando que este atentaría contra el deber de todo funcionario público de denunciar los hechos de que toma conocimiento en el ejercicio de su cargo.²⁸ Sobre esto, un abogado del Ministerio Público aclaró que las labores del Comité justificaban esta excepción respecto de la obligación genérica que tienen todos los funcionarios públicos.²⁹
20. El Senado finalmente aprobó el proyecto sin más modificaciones al artículo 11, enviándose con esta nueva redacción a la Cámara de Diputados para el Tercer Trámite de Constitucional.
21. Una vez que el proyecto volvió a discutirse en Sala de la Cámara de Diputados, el diputado Tucapel Jiménez indicó que los cambios realizados por el Senado, incluyendo el deber de hacer denuncias ante el Ministerio Público serían cambios importantes que debieran ser aprobados sin ningún problema.³⁰ Por su parte, el diputado Naranjo volvió a reiterar la importancia del rol de denuncia del Mecanismo, indicando que dicha institución “*se abocará a la prevención y a denunciar las vulneraciones a los derechos humanos que detecte*”.³¹ En cambio, el

²⁴ *Ibid*, p. 116.

²⁵ Historia de la Ley, Boletín de Indicaciones, p. 154.

²⁶ *Ibid*, p. 154.

²⁷ Historia de la Ley, Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, p. 185.

²⁸ *Ibid*, p. 186.

²⁹ *Ibid*, p. 186.

³⁰ Historia de la Ley, Discusión en Sala, Cámara de Diputados, p. 246.

³¹ *Ibid*, p. 250.

diputado Sanhuesa señaló que “[p]uesto que el espíritu del proyecto de ley es el diálogo constructivo con el fin de prevenir la tortura y proponer cambios, no es función del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura denunciar hechos de tortura”.³² Sin embargo, no existieron más modificaciones al artículo 11, que finalmente se transformó en el artículo 10 en la versión final del Proyecto que fue aprobado por el Congreso —al eliminarse el antiguo artículo 10 del Proyecto de Ley, que disponía fuero para los expertos y expertas del Comité—.

22. Del examen de la Historia de la Ley, es posible constatar que existió un cierto consenso entre los parlamentarios sobre la importancia de que el Comité no se transformara en un organismo de denuncia, pues ello podría ser incompatible con el desempeño de sus labores. Fue dicha consideración la que justificaría la excepción a la obligación de denuncia que tienen los demás funcionarios públicos. Ahora bien, sin perjuicio de que existió algún debate sobre esta excepción, éste no incluyó un análisis de la expresión “*riesgo vital*” y su posible determinación por el Comité. La única referencia fue la realizada por el diputado Bellolio, mencionada *supra*, y que parece haber homologado los conceptos “*riesgo vital*” con la existencia de torturas.³³ Sin embargo, la Historia de la Ley no permite determinar qué se entenderá por riesgo vital a efectos de gatillar la obligación de denuncia de los miembros del Comité.

B. Otras disposiciones legales que hacen referencia al concepto de “riesgo vital”

23. El concepto de riesgo vital no es exclusivo de la Ley 21.154, sino que el mismo también aparece en otros cuerpos normativos.
24. En efecto, el DFL 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 (que contiene la denominada “Ley de Urgencias”) incluye varias referencias al concepto de “emergencia” o “urgencia”.³⁴ Dichos conceptos son definidos en el artículo 3 del Decreto Supremo N°369 (“Reglamento del Régimen de Prestaciones de Salud”) de 1985 del Ministerio de Salud, como “*toda condición de salud o cuadro clínico que involucre estado de riesgo vital o riesgo de secuela funcional grave para una persona, y por ende, requiere atención médica inmediata e impostergable*” (énfasis agregado). La misma disposición también indica que “*[l]a condición de salud o cuadro clínico de emergencia o urgencia debe ser determinado en la primera atención médica en que la persona sea atendida, ya sea en una unidad de urgencia pública o privada, por el diagnóstico efectuado por un médico cirujano de acuerdo con un protocolo dictado por el Ministerio de Salud y aprobado por decreto suscrito bajo la fórmula ‘Por Orden del Presidente de la República’. Dicha condición de salud o cuadro clínico deberá ser certificada por el médico que la diagnosticó*”.³⁵
25. Como puede verse entonces, en conformidad con dicha disposición, el concepto de “*riesgo vital*” está asociado a la necesidad inmediata e impostergable de contar con atención médica.

³²Ibid, p. 252

³³ Historia de la Ley, Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, p. 43: “*aparece obvio que cuando hay torturas ello implica riesgo vital*”.

³⁴ Ver artículos 18, 32(2), 141, entre otros.

³⁵ No ha sido posible obtener copia de dicho Protocolo, siendo posible que el mismo no haya sido emitido hasta la fecha.

Disponiéndose además que la determinación del riesgo vital es una que debe ser realizada por un médico cirujano.

26. Por su parte, con fecha 24 de abril de 2012 se publicó la Ley 20.584 “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”. El artículo 10 de esa normativa, que regula el derecho de toda persona a ser informada, incluye la siguiente disposición en su párrafo tercero:

“Tratándose de atenciones médicas de emergencia o urgencia, es decir, de aquellas en que la falta de intervención inmediata e impostergradable implique un riesgo vital o secuela funcional grave para la persona y ella no esté en condiciones de recibir y comprender la información, ésta será proporcionada a su representante o a la persona a cuyo cuidado se encuentre, velando porque se limite a la situación descrita. Sin perjuicio de lo anterior, la persona deberá ser informada, de acuerdo con lo indicado en los incisos precedentes, cuando a juicio del médico tratante las condiciones en que se encuentre lo permitan, siempre que ello no ponga en riesgo su vida. La imposibilidad de entregar la información no podrá, en ningún caso, dilatar o posponer la atención de salud de emergencia o urgencia.” [Énfasis agregado]

27. En un sentido similar, el artículo 15(b) del mismo cuerpo normativo también dispone como excepción al derecho de los pacientes de entregar su consentimiento en relación con las atenciones de salud, el caso de la persona que se encuentre en riesgo vital “*de no mediar atención médica inmediata e impostergradable*”.
28. En consecuencia, la referida ley confirma la interpretación ya esbozada, en el sentido que el concepto de “riesgo vital” se vincula con la necesidad de contar con atención médica inmediata e impostergradable.
29. A su vez, con fecha 6 de junio de 2015 se publicó la Ley 20.850 “Crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos”. En su artículo 3, dicha ley dispone un mecanismo de cobertura financiera, que en su tercer párrafo indica:

“No obstante, tratándose de una condición de salud que implique urgencia vital o secuela funcional grave, en los términos señalados en el decreto N°369, del Ministerio de Salud, de 1985, que aprueba el Reglamento del Régimen de Prestaciones de Salud y sus modificaciones, y que, en consecuencia, requiera hospitalización inmediata e impostergradable en un establecimiento diferente de los contemplados en la Red de Prestadores aprobados por el Ministerio de Salud, el beneficiario tendrá igualmente derecho a las prestaciones incluidas en el Sistema de Protección Financiera de que trata esta ley, hasta que el paciente se encuentre en condiciones de ser trasladado a alguno de los prestadores aprobados por el Ministerio de Salud”. [Énfasis agregado]

30. Nuevamente y en conformidad con dicha disposición, el concepto “*urgencia vital*” se encuentra definido como aquel que requiere “*hospitalización inmediata e impostergradable*”.
31. Una última disposición relevante es el artículo 119(1) del Código Sanitario, que también hace referencia al concepto de “riesgo vital” para efectos de determinar la posible interrupción del embarazo. El artículo dispone que caen bajo dicha hipótesis los casos en

que “la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida”. Si bien el concepto no es mayormente definido en el Código Sanitario, el artículo 119 bis del mismo cuerpo normativo indica que a efectos de realizar dicha intervención, “se deberá contar con el respectivo diagnóstico médico”. En consecuencia, bajo dicho cuerpo normativo, puede verse nuevamente que la determinación de riesgo vital es una que corresponde realizar al profesional de la salud.

32. Finalmente, cabe destacar que la Excma. Corte Suprema también ha debido examinar el alcance del término “riesgo vital” al momento de resolver recursos de protección presentados por pacientes que exigen coberturas de salud frente a ciertos eventos de urgencia. En ese sentido, en sentencia de 7 de noviembre de 2012 (Rol 5.513-2012), la Excma. Corte, haciendo referencia al Decreto Supremo N°369 de 1985, ya referido *supra*, indicó:

*“Que de las normas referidas en el fundamento precedente es posible concluir que tanto la calificación de ‘urgencia’ y de ‘riesgo vital’ como la de ‘paciente estable’ son actos formales que deben ser realizados por un médico cirujano en la primera atención médica en que la persona sea atendida o cuando se produzca un cambio significativo en su estado de salud como al de paciente estable, y una vez que esta última declaración se haya formulado surge la obligación para el Servicio de Salud de instar por el traslado del paciente al centro asistencial de la red de salud que determine o a su domicilio, según sea el caso, ello a menos que la paciente o quien represente su voluntad o intereses manifieste en forma clara y expresa su decisión de seguir en el centro asistencial al que ingreso de urgencia”.*³⁶ [Énfasis agregado]

33. En consecuencia, del examen de la normativa y la jurisprudencia relevante, resulta claro que bajo la legislación chilena, la hipótesis de “riesgo vital” es una que se vincula con la necesidad inmediata e impostergable de hospitalización. Sin embargo, al mismo tiempo, los textos legales hacen referencia a la determinación de dicha circunstancia por un médico cirujano. Si bien dicho requisito resulta razonable en ese contexto –dado el ámbito de aplicación de las respectivas normas, que presuponen la presencia de la persona en cuestión en un centro de salud–, ello no significa que el mismo criterio deba ser seguido a efectos de interpretar el artículo 10 de la Ley 21.154. Como veremos, existen otras consideraciones a nivel internacional que deben orientar una interpretación más flexible de dicho requisito.

C. Estándares internacionales

34. Desde el punto de vista internacional, existen algunos lineamientos que pueden ser útiles para la correcta interpretación del alcance de la obligación de denuncia del Comité prevista en el artículo 10 de la Ley 21.154.
35. Como cuestión preliminar, debe tenerse presente que uno de los principios básicos de interpretación en materia del derecho internacional de los derechos humanos es el principio

³⁶ Ver en el mismo sentido Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 13 de noviembre de 2012 (Rol 5.515-2012); Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 8 de marzo de 2017 (Rol 46.534-2016) o Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 21 de agosto de 2017 (Rol 21.787-2017).

pro homine, bajo el cual “la dignidad del individuo es una preocupación primordial al interpretar los derechos especificados en el derecho internacional de los derechos humanos”.³⁷

36. Este principio interpretativo ha quedado bien reflejado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), que ha señalado preferir aquella interpretación “que proporcione el mayor grado de protección a los seres humanos bajo su tutela”,³⁸ y que se oriente “en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración del sistema”.³⁹ En el mismo sentido, el artículo 29(2) de la Convención Americana de Derechos Humanos indica que en el ejercicio interpretativo no puede limitarse el goce y ejercicio de ningún derecho que haya sido reconocido de acuerdo con las leyes de los Estados. Ello confirma que debe preferirse una interpretación que reconozca y de pleno cumplimiento a las garantías de las personas privadas de libertad”.
37. En consecuencia, el término “riesgo vital” y la consecuente obligación de denunciar que recae sobre los miembros del Comité, debe ser interpretado teniendo a la vista, de manera primordial, los intereses de las personas que se encuentren en una situación de privación de libertad que caiga bajo la esfera de competencia del Mecanismo.
38. Otro principio interpretativo aplicable en materia de derecho internacional de los derechos humanos, que se vincula directamente con el anterior, es el principio del *effet utile* o efecto útil. Al respecto, la Corte IDH ha señalado que la protección de la persona humana “requiere que los Estados garanticen y respeten los derechos contenidos en [la Convención Americana de Derechos Humanos] de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (*effet utile*)”.⁴⁰ En consecuencia, la regla prevista en el artículo 10 y la obligación de denuncia en casos de “riesgo vital” debe ser interpretada de manera de que ésta otorgue una protección práctica y efectiva a las personas privadas de libertad.
39. Considerando ambos criterios interpretativos, si bien es cierto que la legislación chilena utiliza el concepto “riesgo vital” para referirse a una condición de salud que es acreditada por un médico cirujano, no es posible interpretar la disposición prevista en el artículo 10 de la Ley 21.154 exigiendo tal requisito, que será imposible de cumplir en la mayoría de los casos. En efecto, exigir la presencia y certificación previa de un profesional de la salud para efectos de gatillar el deber de denuncia, supondría que dicha obligación sólo surgiría en un número limitado de casos –sólo aquellos en que el Comité pueda garantizar la presencia de

³⁷ Pasqualucci, Jo M. *The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 12. Traducción libre, original en inglés: “the dignity of the individual is of primary concern when interpreting the rights specified in international human rights law”.

³⁸ Corte IDH. *Caso Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago*. Sentencia de 1 de septiembre de 2001 (Excepciones Preliminares), párr. 70.

³⁹ Corte IDH. *Asunto Viviana Gallardo*. Decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. 16.

⁴⁰ Corte IDH, *Caso Vargas Areco vs Paraguay*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr. 85. En un sentido similar ver Corte IDH, *Caso Lori Berenson Mejía vs Perú*. Sentencia de 25 de noviembre de 2004, párr. 220: “La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del *effet utile*)”.

- un profesional de la salud en las visitas—, y supondría además una interpretación restrictiva de esta disposición, que va en beneficio directo de las personas privadas de libertad.
40. En efecto, es posible que la situación de “riesgo vital” en la que se encuentre una persona privada de libertad no se refiera exclusivamente a una condición de salud frágil (de aquellas que pueden ser acreditadas por un médico), sino a la existencia de amenazas en su contra que generen un riesgo real a su vida. En consecuencia, interpretar dicha disposición exigiendo la presencia de un profesional de la salud sería incompatible con las reglas del *effet utile* y el principio *pro homine*, ya reseñadas.
41. Asimismo, resulta también interesante examinar la obligación de denuncia prevista en el artículo 10 a la luz de otras disposiciones internacionales. En efecto, existen una serie de documentos a nivel internacional y comparado que establecen deberes de denuncia. En general dichos deberes están sujetos a ciertas limitaciones que derivan del respeto al principio de confidencialidad y la obtención del consentimiento de la víctima, que se examinarán *infra*, en la Sección IV de este documento.
42. Ahora bien, muchas de las reglas a nivel internacional que imponen deberes de denuncia se han enfocado en actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y no en un deber general de denuncia respecto de otros hechos cometidos al interior de un centro de privación de libertad, que pudieran implicar riesgo vital. Por ejemplo, el artículo 10 de la Convención de la Tortura establece la obligación de los Estados de educar e informar sobre la prohibición de la tortura al personal encargado de la aplicación de la ley, al personal médico, a los funcionarios públicos y a otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. Esta disposición ha sido interpretada por la doctrina imponiendo la obligación de capacitar al personal sobre su deber de denunciar casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.⁴¹ Sin embargo, ello no parece extenderse a otros hechos de violencia.
43. Por su parte, a nivel comparado e internacional, existen varios documentos que refuerzan el deber de denunciar actos graves de violencia cometidos al interior de recintos de privación de libertad, pero muchas de ellas se refieren expresamente a profesionales de la salud (incluyendo un deber de denunciar actos de violencia sexual⁴² o tortura⁴³), sin otorgar mayor claridad sobre los deberes de actuación de personas sin capacitación médica.

⁴¹ Monina, G. “Article 10. Training of Personnel”, En: Nowak, M.; Birk, M. y Monina, G. *The United Nations Convention against Torture and its Optional Protocol: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 314.

⁴² Por ejemplo, en Estados Unidos, un Informe para poner fin a la violación al interior de los centros de privación de libertad destacaba que los profesionales de la salud tienen un deber de denunciar cualquier indicio de abuso sexual, debiendo informar a los prisioneros sobre este deber antes de proporcionar tratamiento. *National Prison Rape Elimination Commission Report*, 2009, pp. 15, 135.

⁴³ Consejo de Derechos Humanos. *Resolución 10/24. La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: la función y la responsabilidad del personal médico y otro personal de salud*. 27 de marzo de 2009, párr. 5; International Forensic Expert Group, *Statement on access to relevant medical and other health records and relevant legal records for forensic medical evaluations of alleged torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, 2012, p. 47; Asociación Médica Mundial, *Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Responsabilidad de los Médicos en la Documentación y la Denuncia de Casos de Tortura o Trato Cruel, Inhumano o Degradante*, 2003, párr. p.1

44. Otro aspecto interesante a examinar es la regulación comparada de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (“MNPT”) que han sido establecidos en otros países, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. En efecto, la revisión de la normativa aplicable demuestra que varios de ellos también tienen un mandato legal o reglamentario que les obliga a denunciar distintos crímenes o delitos de los que toman conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, en Argentina, se impone la obligación al Comité de comunicar a las autoridades nacionales o provinciales, además de los magistrados y funcionarios judiciales que correspondan, “*la existencia de hechos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*” respecto de los cuáles hayan recibido denuncias o hayan podido constatar.⁴⁴ Por su parte, el MNPT de Francia deberá comunicar a las autoridades competentes cuando encuentre “*una violación grave de los derechos fundamentales de una persona privada de libertad*”, y está sujeto además a la obligación general de poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos constitutivos de delito.⁴⁵ A su vez, en Guatemala, el MNPT deberá “*comunicar y/o denunciar a los órganos y autoridades competentes, la posible existencia de delitos u otras situaciones que requieran de investigación*”,⁴⁶ mientras que el MNPT de Panamá también está sujeto a una obligación genérica de denunciar cualquier hecho constitutivo de delito del que tome conocimiento.⁴⁷ Por su parte, en Uruguay, la Institución Nacional de Derechos Humanos (que actúa como MNPT) está obligado a poner en conocimiento de la justicia los hechos que pueden verificar “*un supuesto presumiblemente delictivo*”,⁴⁸ sea que tome conocimiento de ellos por denuncias de terceros o por sus propias investigaciones.
45. En otros países, los miembros de los respectivos Mecanismos no están sujetos a la obligación de denunciar, pero sí están facultados a hacerlo. Por ejemplo, en Brasil, el MNPT está autorizado a requerir a la autoridad competente que inicie procedimiento cuando existan indicios de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.⁴⁹ Sin embargo, ello está regulado como una prerrogativa y no un deber de los miembros del organismo. Lo mismo ocurre en el caso de Honduras, donde se incluye como una de sus atribuciones el “[c]omunicar a las autoridades competentes, todo acto de tortura y otros tratos crueles,

⁴⁴ Argentina. Artículo 7(ñ), Ley N°26.827 del año 2013 “Créase el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

⁴⁵ Francia. Artículo 9 de la Ley N°2007-1545 de 2007 «Instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté». Ver también párrafo 71 Règlement intérieur Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

⁴⁶ Guatemala. Artículo 12(e) del Decreto N°40-2010, “Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

⁴⁷ Panamá, Artículo 13, Ley N°6 del año 2017 “Que Crea el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

⁴⁸ Uruguay. Artículo 30 de la Ley N°18.446 “Institución Nacional de Derechos Humanos”. Ver artículo 83 de la Ley que indica que esta institución realizará las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

⁴⁹ Brasil. Artículo 9, Ley 12.847 de 2013 “Institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; e dá outras providências”. Ver igualmente Artículo 21, Regimento Interno do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

inhumanos o degradantes del que tenga conocimiento”,⁵⁰ y con el de México donde se establece la facultad de “[d]enunciar ante la autoridad competente, los casos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes de los que tenga conocimiento”.⁵¹ Ahora bien, cabe destacar que el Reglamento de este último Mecanismo sí dispone la obligación del personal adscrito al MNPT de presentar la denuncia a la autoridad competente en caso que tenga conocimiento de hechos que pudieren constituir “algún delito”.⁵²

46. En cambio, una obligación similar no se incluye expresamente en las leyes que crean los MNPT en Bolivia,⁵³ Costa Rica,⁵⁴ Ecuador,⁵⁵ España,⁵⁶ Nicaragua,⁵⁷ Paraguay,⁵⁸ Perú,⁵⁹ o Suiza,⁶⁰ aunque es posible que en algunos de esos casos exista una obligación general de denuncia para funcionarios públicos, que no aparezca en la ley respectiva.
47. Como puede verse entonces, un examen de la regulación comparada de otros MNPT no resulta directamente útil para efectos de interpretar el término “*riesgo vital*” previsto en la Ley 21.154, puesto que ninguna de las legislaciones revisadas contiene un término similar a efectos de gatillar la obligación de denunciar. En efecto, la fórmula habitual parece ser limitar dicha obligación a casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o en su defecto, establecer una obligación general de denuncia respecto de cualquier delito. Sin embargo, la revisión de estos estándares resulta útil para ratificar la importancia del acto de denuncia por parte de los miembros del MNPT, que se encuentra reconocida en diversas variantes en un gran número de jurisdicciones. Asimismo, la revisión de la legislación

⁵⁰ Honduras. Artículo 13(10), Decreto N°136-2008 “Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

⁵¹ México. Artículo 78 X de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2017.

⁵² México. Artículo 37 del Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

⁵³ Bolivia. Ver Ley N°474 del año 2013 “Ley del servicio para la prevención de la tortura”. Ver igualmente Reglamento de la Ley del Servicio para la Prevención de la Tortura, DS N° 2082, 21 de agosto de 2014.

⁵⁴ Costa Rica. Ver Ley 9.204 de 2014 “Creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

⁵⁵ Ecuador. Ver Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (artículo 22: la Defensoría del Pueblo implementará un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

⁵⁶ España. Ver Ley Orgánica 31/1982 “Del Defensor del Pueblo”. En conformidad con la Ley Orgánica 1/2009 se dispuso que el Defensor del Pueblo ejercería las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

⁵⁷ Nicaragua. Ver Ley 212 de 1995 “Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”. En conformidad con el Acuerdo Presidencial No. 04-2012, dicha Procuraduría fue designada como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

⁵⁸ Paraguay. Ver Ley 4288/2011 “Del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”.

⁵⁹ Perú. Ver Ley 30.394 de 2015 “Ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo como Órgano Encargado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

⁶⁰ Suiza. Ver Loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture de 2009.

comparada confirma que en ninguna de dichas jurisdicciones existiría la necesidad de contar con la certificación de un médico para efectos de gatillar dicha obligación.

48. Otro aspecto que puede ser relevante para efectos de interpretar esta obligación de denuncia, es el alcance de la obligación de los Estados en la protección del derecho a la vida de las personas privadas de libertad.
49. Sobre este punto, la Comisión Interamericana (“CIDH”) ha señalado que “[c]on respecto a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, según la cual su deber de garantizar [el derecho a la vida] es aún mayor”.⁶¹ Asimismo, en casos en que existiera un riesgo a la vida de las personas privadas de libertad, la CIDH ha indicado que “el Estado puede ser internacionalmente responsable por la falta de prevención o por su actuar manifiestamente negligente en situaciones que pudieron ser evitadas o mitigadas si las autoridades competentes hubiesen adoptado las medidas de prevención adecuadas, y/o si hubiesen reaccionado de forma eficaz ante la amenaza o el riesgo producidos”.⁶² De igual manera, la Comisión ha señalado que “[s]iendo la prisión un lugar donde el Estado tiene control total sobre la vida de los reclusos, sus obligaciones hacia éstos incluyen, entre otras, la de proteger a los reclusos contra hechos de violencia provenientes de cualquier fuente”.⁶³ En consecuencia, en el evento que miembros del Comité tuvieran conocimiento de una situación que pudiera poner en riesgo la vida de una persona privada de libertad, y no tomaran medidas para reaccionar ante dicha amenaza, denunciándolo a las autoridades competentes, ello podría acarrear la responsabilidad del Estado, dada su posición de garante y su deber de actuar frente a riesgos a la vida de las personas privadas de libertad.
50. Una conclusión similar puede extraerse del examen de la jurisprudencia de la Corte IDH. La misma también se ha referido a la especial protección a la que tienen derecho las personas privadas de libertad. Por ejemplo, en el caso *Vélez Loor vs Panamá*, la Corte sostuvo que “[c]omo responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia”.⁶⁴ Lo mismo ha sido reconocido en varias otras oportunidades.⁶⁵
51. Cabe destacar que este deber de actuar de las autoridades del Estado –que incluiría a los miembros del Comité– opera incluso respecto de riesgos a la vida que deriven de conductas de particulares. Como la Corte aclaró en el caso *Masacre de Mapiripán vs. Colombia*, actos de

⁶¹ CIDH, *Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*. 31 de diciembre de 2011 (OEA/Ser.L/V/II), párr. 270.

⁶² *Ibid*, párr. 285. Énfasis agregado.

⁶³ CIDH, *Informe No. 67/06, Caso 12.476, Fondo, Oscar Elías Biscet y otros, Cuba*, 21 de octubre de 2006, párr. 149. Énfasis agregado.

⁶⁴ Corte IDH, *Caso Vélez Loor vs Panamá*, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 198. Énfasis agregado.

⁶⁵ Ver por ejemplo: Corte IDH, *Caso Neira Alegría y otros vs Perú*, Sentencia de 19 de enero de 1995 (Fondo), párr. 60; Corte IDH, *Caso “Instituto de Reeducción del Menor” vs Paraguay*, Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 152; Corte IDH, *Caso Fleury y otros vs Haití*, Sentencia de 23 de noviembre de 2011 (Fondo y Reparaciones), párr. 84; Corte IDH, *Caso Díaz Peña vs Venezuela*, Sentencia de 26 de junio de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 135; Corte IDH, *Caso Hernández vs Argentina*, Sentencia de 22 de noviembre de 2019 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 56; Corte IDH, *Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs Venezuela*, Sentencia de 5 de julio de 2006 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 87; entre otros.

particulares pueden ser atribuidos al Estado cuando el Estado incumple su obligación de tomar medidas para asegurar la protección de los derechos humanos, por acción u omisión de sus agentes, en casos en que se encuentra en una posición de garante.⁶⁶

52. En un sentido similar, en el caso *Ximenes Lopes vs. Brasil*, la Corte señaló que el Estado tenía el “*deber de cuidar y de prevenir la vulneración de la vida y de la integridad personal*” respecto de personas que se encuentran en su custodia.⁶⁷
53. En términos generales, el deber del Estado frente a actos de particulares es “*prevenir razonablemente*” las violaciones a los derechos humanos.⁶⁸ Precizando el alcance de esta obligación de prevención la Corte ha indicado que deben concurrir 3 elementos: (i) el conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato; (ii) dirigida a un individuo o grupo de individuos; (iii) posibilidades razonables de prevenir o evitar el riesgo.⁶⁹ De hecho, la Corte ha indicado que cuando haya conocimiento de que existía “*un riesgo real e inmediato*” a las víctimas, “*es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades*”.⁷⁰
54. Los referidos criterios son plenamente aplicables para el caso. En efecto, en caso que los miembros del Comité tomen conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato a la vida, deben tomar aquellas medidas razonables para prevenir y evitar el riesgo, que requieren una denuncia inmediata a las autoridades. Imponer cualquier requisito adicional de calificación –como una certificación médica o cualquier otra– no permitiría la actuación pronta que ha exigido la jurisprudencia.
55. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”) también ha enfatizado el especial deber de protección que tienen las autoridades respecto de las personas en custodia, dada su situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en *Mustafayev v. Azerbaiyán*, el TEDH sostuvo que “*las personas bajo custodia están en una posición vulnerable y las autoridades tienen el deber de protegerlas*”,⁷¹ y que la obligación de proteger la vida de los individuos bajo custodia “*también*

⁶⁶ Corte IDH. *Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia*, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

⁶⁷ Corte IDH, *Caso Ximenes Lopes vs Brasil*, Sentencia de 4 de julio de 2006, párr. 146.

⁶⁸ Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras*, Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), párr. 174.

⁶⁹ Corte IDH, *Caso de la Masacre del Pueblo Bello vs Colombia*, Sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123.

⁷⁰ Corte IDH, *Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México*. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 283.

⁷¹ TEDH. *Case of Mustafayev v. Azerbaijan* (Application No. 47095/09). Judgment of 4 May 2017, párr. 53 (traducción libre, original en inglés). Sobre la misma idea de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y el deber de las autoridades de protegerlas, ver igualmente TEDH, *Case of Slimani v. France* (Application No. 57671/00). Judgment of 27 July 2004, para. 27; TEDH, *Case of Karsakova v. Russia* (Application No. 1157/10). Judgment of 27 November 2014, párr. 48.

implica una obligación de las autoridades de proveerles con la atención médica necesaria para proteger sus vidas”,⁷² y para “*prevenir un desenlace fatal*”.⁷³

56. De igual manera, el TEDH también ha hecho referencia al caso en que existan amenazas a la vida de una persona que provengan de un particular, señalando que el Estado habrá violado su obligación positiva de proteger el derecho a la vida si se acredita que las autoridades “*conocían o debían haber sabido en el momento de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de una persona o personas identificadas por los actos delictivos de un tercero y no tomaron medidas dentro del ámbito de sus competencias que, juzgadas razonablemente, cabría esperar que evitaran ese riesgo*”.⁷⁴ El Tribunal ha enfatizado dicho deber en caso de una persona que se encuentra puesta bajo custodia policial, dada la situación de dependencia del Estado que existe, que obliga a las autoridades a tomar medidas razonables para evitar un desenlace fatal.⁷⁵
57. Como puede verse, el TEDH también hace referencia a la existencia de un riesgo real a la vida como una circunstancia que impone al Estado la obligación de adoptar medidas razonables, y que esta obligación es especialmente relevante en el caso de personas que estén privadas de libertad.
58. En suma, la especial posición de garante del Estado respecto de las personas privadas de libertad, y su obligación de proteger la vida y salud de ellas –según ha sido reconocido por la CIDH, la Corte IDH, y también por el TEDH–, debiera llevar a interpretar la obligación de denuncia prevista en el artículo 10 de la Ley 21.154 en términos amplios, de manera de permitirle al Estado actuar oportunamente frente a amenazas a la vida de personas privadas de libertad. En efecto, es precisamente esa posición de garante y la especial vulnerabilidad de las personas privadas de libertad la que justifica una interpretación amplia de la obligación de denuncia en casos de riesgo vital.
59. Por ello, una interpretación del artículo 10 de la Ley 21.154 a la luz de los estándares de interpretación en materia de derechos humanos, y de la especial obligación del Estado de proteger a las personas privadas de libertad, permite concluir que el deber de los miembros del Comité de presentar una denuncia en casos de riesgo vital, debe ser interpretado de manera extensiva, sin requerir la certificación de un médico u otro profesional de la salud, sino bastando con la constatación de las Expertas o el personal de apoyo de que dicho riesgo existe, a efectos de gatillar la obligación de poner los antecedentes en conocimiento del

⁷² TEDH. *Case of Mustafayev v. Azerbaijan* (Application No. 47095/09). Judgment of 4 May 2017, párr. 54 (traducción libre, original en inglés).

⁷³ TEDH. *Affaire Taïs v. France* (Requête no 39922/03). Arrêt 1er juin 2006, párr. 98 (traducción libre, original en francés). Ver igualmente TEDH, *Affaire Hüylü c. Turquie* (Requête no 52955/99). Arrêt 16 novembre 2006, párr. 58; TEDH, *Case of Jasinskis v. Latvia* (Application No. 45744/08). Judgment of 21 December 2010, párr. 60.

⁷⁴ TEDH, *Case of Osman v. The United Kingdom* (87/1997/871/1083), Judgment, 28 October 1998, párr. 116. Traducción libre, original en inglés: “*the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual or individuals from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk*”. Ver, en el mismo sentido, TEDH, *Paul and Audrey Edwards v. The United Kingdom* (Application No. 46477/99), Judgment, 14 March 2002, párr. 54-55.

⁷⁵ TEDH, *Affaire Oirga et autres c. Roumanie* (Requête No. 26246/05), Arrêt 25 janvier 2011, párr. 64.

Ministerio Público. Lo anterior, sujeto a los límites que serán revisados *infra* en lo relativo al deber de confidencialidad y la necesidad de obtener el consentimiento de la persona involucrada.

III. SOBRE LA RELEVANCIA DEL PRESUNTO AUTOR DE LA TORTURA A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL DEBER DE DENUNCIA

60. Como ya se adelantaba, el artículo 10 de la Ley 21.154 dispone que los expertos y el personal de apoyo del Comité de Prevención contra la Tortura no tendrán obligación de denunciar los hechos delictivos de los que tomen conocimiento en sus visitas, salvo respecto de aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad –según fue examinado en la sección anterior–, o en caso que existan posibles víctimas de algunos de los actos “*definidos como tortura en la letra a) del artículo 2*” de la misma ley. Es esta segunda hipótesis la que nos interesa revisar en esta sección.
61. El artículo 2(a) de la Ley 21.154 incluye una definición de tortura del siguiente tenor:

Artículo 2.- Definiciones. Para los fines de la presente ley se entenderá por:

a) Tortura: todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o confesión; de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido; o de intimidarla o coaccionarla; o en razón de discriminación fundada en motivos como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género; la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud, la situación de discapacidad, o con cualquier otro fin.

Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines referidos en el inciso precedente.

62. Como puede verse, la definición de tortura prevista en el artículo 2(a) de la Ley 21.154 incluye dos elementos: (a) la inflicción intencional de dolor o sufrimiento grave a una persona (ya sean físicos, sexuales o psíquicos); (b) una cierta finalidad. Notablemente, dicha definición no incluye el requisito de la participación de un funcionario público.
63. En contraste, el artículo 150A del Código Penal chileno –incorporado por medio de la Ley 20.968 que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes– define tortura en los siguientes términos:

El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura, será penado con presidio mayor en su grado mínimo. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.

La misma pena se aplicará al particular que, en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación de un empleado público, o con el consentimiento o aquiescencia de éste, ejecutare los actos a que se refiere este artículo.

Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.

Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines referidos en el inciso precedente. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad.

64. De esta manera, si bien la definición del acto de tortura es similar en ambos cuerpos normativos —el Código Penal también exige: (a) la inflicción intencional de dolor o sufrimiento grave; y (b) una cierta finalidad, aunque sin incluir la cláusula genérica de “cualquier otro fin”—, lo cierto es que el Código Penal tipifica dicha conducta sólo respecto de empleados públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, actúen a instigación de un empleado público o actúen con su consentimiento o aquiescencia. En consecuencia, a efectos del delito de tortura, la determinación del sujeto activo es fundamental.
65. Sin embargo, ese no es el caso de la Ley 21.154, que no incorpora en su artículo 2 un requisito relativo a la participación de un funcionario público o un particular cumpliendo funciones públicas. Por tanto, un acto que cumpliera con los dos requisitos ya vistos (inflicción intencional de dolor o sufrimiento grave, y una cierta finalidad), pero que fuera cometido por una persona distinta de un funcionario público, cabría dentro del ámbito de la Ley 21.154 y del deber de denunciar previsto en el artículo 10, sin importar el sujeto activo de la conducta.
66. En efecto, el artículo 10 de la Ley 21.154 es claro en establecer una obligación de denunciar respecto de los hechos que cumplan con la definición de tortura de la letra a) del artículo 2 de la Ley 21.154, y no respecto hechos que constituyan el “delito” de tortura, en los términos del artículo 150A del Código Penal.
67. Sin embargo, para mayor claridad y precisión sobre este punto, resulta útil acudir a la Historia de la Ley y a la discusión que ahí se generó sobre la diferencia entre el artículo 2 de la Ley 21.154 y la disposición del artículo 150A del Código Penal.

A. Historia de la Ley

68. La definición de tortura prevista en la Ley 21.154 venía ya en el Proyecto de Ley presentado por la Presidenta Bachelet, que incluía una definición casi idéntica de tortura, en los siguientes términos:

Artículo 2.- Definiciones. Para los fines de la presente ley se entenderá por:

a) Tortura: todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad.

Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines referidos en el inciso precedente.⁷⁶

69. Como puede verse, más allá de algunas precisiones de redacción, la mayor diferencia entre el Proyecto de Ley, según este aparecía en el Mensaje Presidencial, y el texto actual del artículo 2 de la Ley 21.154 es que el proyecto original no contenía la frase final “o con cualquier otro fin” al final del párrafo primero de la letra (a). Sin embargo, el texto del Mensaje Presidencial tampoco incluía el requisito de la intervención de un funcionario público, tal y como se prevé en el Código Penal.
70. De hecho, la diferencia entre la definición de tortura del proyecto de ley y la prevista en el artículo 150A del Código Penal o en otros textos internacionales fue discutida en el trámite legislativo. Por ejemplo, en el marco de la discusión del proyecto en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, mientras que el Director Ejecutivo del Observatorio Social Penitenciario manifestó que estaba de acuerdo con la definición que se daba de la tortura,⁷⁷ el coordinador del Observatorio para el cierre de las Escuelas de las Américas (SOA Watch) indicó en cambio que la definición de tortura del artículo 2 no se adecuaría con la prevista en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al faltar la referencia a un funcionario público o una persona en el ejercicio de funciones públicas.⁷⁸
71. A su vez, el diputado Jaime Bellolio hizo presente la dificultad con la definición de tortura que se contiene en el artículo 2 y “que es contradictoria con la definición de tortura que se entrega en la ley N°20.968, que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes”, proponiendo en consecuencia que la definición de tortura para estos efectos fuera idéntica a aquella.⁷⁹ Por su parte, el Jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos

⁷⁶ Historia de la Ley, Mensaje, pp. 7-8.

⁷⁷ Historia de la Ley, Informe de la Comisión Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, p. 32.

⁷⁸ *Ibid*, p. 37.

⁷⁹ *Ibid*, p. 42.

- Humanos, aclaró que la definición de tortura en el artículo 2 era exactamente igual a la que está en la ley, *“pero como no se trata de una tipificación necesaria para imputar la responsabilidad penal a una persona, se omite en esta definición el alcance del sujeto activo, porque ello no es procedente”*.⁸⁰ Más adelante, éste también indicó que *“la norma del Código penal, de acuerdo con la modificación introducida por la ley N° 20.968, y el precepto en actual discusión, no son en ningún caso excluyentes”* y que *“[e]l intérprete, en este caso el funcionario del MNPT, trabajará con ambas normas, de manera que a efectos de prevenir, identificar y establecer prácticas en materia de prevención, siempre se verá la definición de tortura que da el Código penal, donde ya hay una mención expresa del funcionario público”*.⁸¹
72. Por su parte, la Jefa del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos también se refirió a la discusión sobre si es necesario o no que quien realice actos de tortura sea o no un funcionario público, indicando que se debe tener en cuenta que *“en los hospitales psiquiátricos sí se puede cometer alguno de los actos que deben ser prevenidos por el MNPT y que están cubiertos en ambas definiciones como se encuentran hasta ahora, porque son lugares en que las personas están privadas de libertad sea por orden judicial o en custodia, como el caso del hospital psiquiátrico”*.⁸²
73. A su vez, el diputado Sergio Ojeda señaló que no estaba de acuerdo con restringir la definición de tortura a los casos en que participaran funcionarios públicos por considerarla restrictiva, señalando *“[h]ay casos en que las torturas se pueden cometer por otras personas que no sean agentes del Estado”*.⁸³ Por su parte, el diputado René Saffirio aclaró que ésta propuesta legislativa no modificaba el Código Penal sino que asume una definición *“para determinar el ámbito de aplicación de labores de prevención que debe desarrollar un órgano”*.⁸⁴ Sin embargo, la definición de tortura no fue objeto de modificaciones.
74. En el segundo trámite legislativo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado volvió a discutir la definición de tortura, pero no para añadir referencia a un sujeto activo, sino con el fin de ampliar las finalidades enumeradas en la definición. A este respecto, la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos indicó que las finalidades mencionadas en la definición de tortura del artículo 2 eran meramente ejemplificadoras y no taxativas, sugiriendo en consecuencia agregar la expresión *“o con cualquier otro fin”*.⁸⁵ En ese sentido, el senador Latorre propuso modificar la definición de tortura incorporando dicha frase.⁸⁶
75. Mientras el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que los miembros del Consejo de dicha institución habían aprobado por unanimidad dicha indicación, pues estaría en línea con la definición de tortura de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que también recoge la cláusula “o

⁸⁰ *Ibid*, p. 43.

⁸¹ *Ibid*, p. 45.

⁸² *Ibid*, p. 45.

⁸³ *Ibid*, p. 45.

⁸⁴ *Ibid*, p. 45.

⁸⁵ Historia de la Ley, Primer Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, p. 114.

⁸⁶ Historia de la Ley, Boletín de Indicaciones, p. 144.

- cualquier otro fin*”,⁸⁷ la Subsecretaria de Derechos Humanos manifestó su opinión contraria, prefiriendo mantener la definición de tortura anterior que reflejaría el mismo concepto del Código Penal, en el artículo 150A.⁸⁸
76. Por su parte, el senador Kast indicó que la frase “*o con cualquier otro fin*” haría perder la fuerza que el legislador le ha dado al concepto de tortura, haciéndola ambigua y confusa y perdiendo coherencia con la definición del Código Penal.⁸⁹ En cambio, el senador Latorre señaló que el objetivo era evitar que existieran supuestos no comprendidos en la definición de tortura.⁹⁰
77. A su vez, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos indicó que en el derecho internacional esta materia está regulada a través de cláusulas no taxativas, como es el caso del sistema interamericano, y se refirió a una posible inconsistencia con la definición del Código Penal, observando que “*un tema es la tipificación del delito de tortura y otro es la prevención de este tipo de actos, que es justamente el objetivo que persigue este mecanismo*”.⁹¹ Más adelante, aclaró que dado que el Mecanismo no tiene dentro de sus funciones patrocinar causas por el delito de tortura sino que tiene un rol preventivo, “*el concepto de tortura que establezca esta ley no se topará con el concepto del delito de tortura*”.⁹² Ello recibió el apoyo de la senadora Muñoz.⁹³ En cambio, tanto el senador Kast como la Subsecretaria de Derechos Humanos reafirmaron la importancia de mantener la consistencia entre la ley vigente y esta definición.⁹⁴ Sin embargo, la indicación para ampliar la definición y agregar la cláusula “*o cualquier otro fin*” fue finalmente aprobada,⁹⁵ quedando dicha redacción en el texto finalmente aprobado por el Congreso, que se transformó luego en la Ley 21.154.
78. Como puede verse entonces, si bien la discusión parlamentaria dio cuenta de la diferencia entre el texto del artículo 2(a) de la Ley 21.154 y la regulación de la tortura en el artículo 150A del Código Penal, no existió un mayor debate sobre el alcance que tendría esa diferencia a efectos del deber de denuncia del Mecanismo. Sin embargo, del examen de la Historia de la Ley, resulta clara la necesidad de distinguir la definición relevante para efectos penales –la del artículo 150A del Código Penal–, de aquella relevante para definir el campo de actuación del MNPT. En efecto, la Ley 21.154 no crea un nuevo tipo penal ni modifica aquel del Código Penal, sino que establece mecanismos de prevención.
79. De hecho, como ya se ha visto, es claro que la definición de tortura prevista en la Ley 21.154 no es idéntica a la del artículo 150A del Código Penal. En efecto, la definición de la Ley

⁸⁷ *Ibid*, p. 160.

⁸⁸ Historia de la Ley, Segundo Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, p. 160.

⁸⁹ *Ibid*, pp. 160-161.

⁹⁰ *Ibid*, p. 161.

⁹¹ *Ibid*, p. 161.

⁹² *Ibid*, p. 161.

⁹³ *Ibid*, p. 162.

⁹⁴ *Ibid*, pp. 161-162.

⁹⁵ *Ibid*, p. 162.

21.154 es más amplia, al incorporar en la definición la cláusula genérica “o con cualquier otro fin” que no está prevista en el Código Penal. Esta diferencia fue evidenciada y explicitada en el proceso legislativo, y a pesar de ello incorporada, lo que permite confirmar que los Congresistas no esperaban que existiera una total uniformidad entre ambas disposiciones.

80. En consecuencia, si bien no hay duda que existe una relación entre ambas disposiciones, pareciera perfectamente posible que el Comité actúe frente a una hipótesis de “tortura” que no se enmarquen en la figura típica del Código Penal. En efecto, no existe ningún impedimento para que el Comité realice una denuncia respecto de un acto que sea definido como tortura en el artículo 2(a) de la Ley 21.154 pero que luego sea calificado de manera distinta por el fiscal a cargo o el tribunal penal correspondiente –sea porque no existe participación de funcionario público, o porque se enmarca en la cláusula general de “cualquier otro fin” que no está prevista en el Código Penal–. Como se refuerza del examen del proceso legislativo, ello no resulta necesariamente problemático, en tanto el rol del Comité se enfoca en la prevención de determinados actos cometidos al interior de recintos de privación de libertad y no la persecución penal.

B. Estándares internacionales

81. A efectos de confirmar la interpretación ya delineada sobre el alcance de la obligación de denuncia prevista en el artículo 10 de la Ley 21.154, puede resultar útil hacer referencia a algunos estándares internacionales sobre la materia.
82. En primer lugar, en la sección anterior ya se hizo referencia a los principios *pro homine* y *effet utile* en la interpretación de las normas de derechos humanos. Ello también es relevante para el análisis de la referencia a “tortura” prevista en la Ley 21.154, y su diferencia con la definición del delito de tortura previsto en el artículo 150A del Código Penal. En efecto, si bien las reglas interpretativas en materia penal y el principio de legalidad exigen que las normas penales se interpreten de manera estricta, ese no es el caso de una norma que busca otorgar protección y garantía a individuos, como es el caso del artículo 10 de la Ley 21.154. En este segundo caso, los principios interpretativos ya referidos exigen preferir aquella interpretación que permita una mayor protección de las garantías de las personas, y que permita un amparo efectivo de sus derechos. Sobre esto, valga recordar que la Ley 21.154 no crea ningún delito ni modifica la regla del artículo 150A del Código Penal, sino que simplemente establece un mecanismo de protección para personas bajo custodia del Estado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.
83. En segundo lugar, debe tenerse presente que, en lo relativo a la definición de la tortura, no todos los instrumentos internacionales establecen la misma definición. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica, en su artículo 7, que “[n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Sin embargo, dicho artículo no impone ningún requisito relativo a la participación de un funcionario público.
84. De hecho, el Comité de Derechos Humanos –órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento del citado Pacto– ha hecho referencia a esta prohibición, indicando que “[e]l Estado Parte tiene el deber de brindar a toda persona, mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra los actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por personas que actúen en

- el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a título privado*”.⁹⁶ En dicho documento se hace referencia específica a la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión,⁹⁷ sin tampoco exigir la actuación de un funcionario público.
85. En términos similares, la Convención Americana de Derechos Humanos indica, en su artículo 5(2), que “[n]adie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Como puede verse, la Convención tampoco indica expresamente que la tortura debe haber sido cometida por un funcionario público.
86. Si bien a la fecha la Corte IDH no parece haber examinado en detalle la posibilidad de que un acto sea calificado como tortura sin referencia a la participación de un funcionario público, ello sí fue considerado por la jueza Cecilia Medina en su voto concurrente en el caso *González y otras (“Campo Algodonero”) vs México*. En tal oportunidad, la jueza Medina hizo referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para evidenciar que ninguna de ellas, ni en su texto ni en su jurisprudencia “*hace alusión al requisito de la exigencia de la participación activa, la aquiescencia o tolerancia, o la inacción de un agente estatal*”.⁹⁸ Por lo mismo, señaló que, en su opinión, la Corte IDH tampoco estaría obligada a aplicar dicho requisito,⁹⁹ bastando acreditarse que la conducta sería atribuible al Estado por no haber cumplido su deber de prevención.¹⁰⁰
87. Como ya adelantaba la jueza Medina, en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, éste tampoco impone como requisito la participación de un funcionario público, limitándose a indicar en su artículo 3: “*Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes*”. En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado que los Estados tienen la obligación de tomar medidas para asegurar que los individuos bajo su jurisdicción no sean sometidos a tortura u otros o penas tratos inhumanos o degradantes, incluyendo aquel que sea administrado por privados.¹⁰¹
88. En cambio, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define tortura en su artículo 1, en los siguientes términos:

“1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o

⁹⁶ Comité de Derechos Humanos, *Observación General N°20 “Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7), 1992, párrs. 2 y 13. Énfasis agregado.*

⁹⁷ *Ibid*, párrs. 10-11.

⁹⁸ Corte IDH, *Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México*, Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Voto Concurrente de la Jueza Cecilia Medina Quiroga, párr. 7.

⁹⁹ *Ibid*, párr. 16.

¹⁰⁰ *Ibid*, párr. 17.

¹⁰¹ TEDH, *Case of Opuş v. Turkey* (Application no. 33401/02), Judgment, 9 June 2009, párr. 159.

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.” [Énfasis agregado]

89. Como puede verse entonces, la Convención contra la Tortura reitera los requisitos de la tortura ya examinados y que se encuentran presentes en el artículo 2 de la Ley 21.154 –la inflicción intencional de dolor o sufrimiento grave a una persona, y una cierta finalidad–. Sin embargo, la Convención añade un requisito adicional, puesto que requiere que dichos dolores “*sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia*”. En ese sentido, la definición de la Convención se acerca a aquella prevista en el artículo 150A del Código Penal, y también a aquella prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que también incluye el requisito de la participación de un funcionario público en su artículo 3.
90. Sin perjuicio de ello, el Comité contra la Tortura ha indicado que el Estado tiene un deber de diligencia respecto de actos de tortura cometidos por privados, indicando que “[l]a negligencia del Estado a la hora de intervenir para poner fin a esos actos [...] facilita y hace posible que los actores no estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que la indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho”.¹⁰² En el mismo sentido, el Subcomité para la Prevención de la Tortura ha indicado desde su primer Informe Anual que “el ámbito de la labor de prevención es amplio y abarca toda forma de maltrato de las personas privadas de libertad que, de no controlarse, podría desembocar en la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.¹⁰³
91. Sobre este punto, es importante tener presente que incluso la definición más estricta prevista en la Convención contra la Tortura, que requiere la participación de un funcionario público, incluye también la hipótesis de que se actúe con su consentimiento o aquiescencia. En consecuencia, un acto de tortura cometido por un sujeto activo distinto –por ejemplo, por otra persona privada de libertad– podría llegar a constituir tortura incluso bajo la definición de la Convención (e incluso del artículo 150A del Código Penal) si se acredita que este fue conocido y no impedido por un funcionario público, especialmente considerando el especial deber de protección que tienen las autoridades respecto de las personas privadas de libertad, como fue desarrollado *supra*. En ese sentido se explica que el Subcomité considere que una forma de maltrato “*podría desembocar en tortura*”, que es

¹⁰² Comité contra la Tortura, *Observación General N°2 – Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes*, UN Doc. CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008, párr. 18. Énfasis agregado.

¹⁰³ Comité contra la Tortura. *Primer Informe Anual del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes* (febrero de 2007 a marzo de 2008). UN Doc. CAT/C/40/2 de 14 de mayo de 2008, párr. 12. Énfasis agregado.

precisamente el caso de un maltrato cometido por una persona distinta de un funcionario público, pero que tenga lugar con en conocimiento e inacción de las autoridades.

92. De hecho, la doctrina explica que los conceptos de “consentimiento” y “aquiescencia” son amplios, y “*pueden interpretarse en el sentido de que abarcan una amplia gama de acciones cometidas por particulares, si el Estado de una forma u otra, permite que continúen dichas actividades*”.¹⁰⁴ En el mismo sentido, el Comité contra la Tortura ha indicado:

*“El Comité ha dejado claro que cuando las autoridades del Estado u otras personas que actúan a título oficial o al amparo de la ley tienen conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o actores no estatales perpetran actos de tortura o malos tratos y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos privados o actores no estatales de conformidad con la Convención, el Estado es responsable y sus funcionarios deben ser considerados autores, cómplices o responsables por otro concepto en virtud de la Convención por consentir o tolerar esos actos inaceptables. La negligencia del Estado a la hora de intervenir para poner fin a esos actos, sancionar a los autores y ofrecer reparación a las víctimas de la tortura facilita y hace posible que los actores no estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Convención, por lo que la indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho”.*¹⁰⁵ [Énfasis agregado]

93. Esta interpretación nuevamente confirma que un acto de tortura cometido por un particular puede caer incluso bajo la definición estricta de tortura prevista en la Convención contra la Tortura, en casos en que las autoridades competentes sean indiferentes o no actúen, lo que puede constituir una forma de autorización de hecho. Lo anterior confirma la importancia de dar cumplimiento al deber de denuncia previsto en el artículo 10 de la Ley 21.154, precisamente para evitar dicha situación de tolerancia aquiescencia.
94. En el mismo sentido, el Comité contra la Tortura señaló en el caso *Hajrizi Džemajil vs Yugoslavia* se refirió a la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de privados. Al respecto, el Comité señaló que la policía, habiendo sido informada del riesgo inmediato y habiendo estado presente al momento de los eventos, no tomó las medidas apropiadas para proteger a los denunciantes, lo que implicaría “aquiescencia” en los términos de la Convención contra la Tortura y una infracción de la referida Convención.¹⁰⁶
95. Finalmente, cabe destacar que el citado artículo 1 de la Convención contra la Tortura, en su párrafo 2, señala expresamente que dicha definición es “*sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance*”. En consecuencia, la misma Convención no puede ser utilizada como argumento para restringir el alcance de la obligación de denuncia prevista en el artículo 10 de la Ley 21.154, en tanto

¹⁰⁴ Zach, G. “Art. 1. Definition of Torture” En: Nowak, M.; Birk, M. y Monina, G. *The United Nations Convention against Torture and its Optional Protocol: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 61.

¹⁰⁵ Comité contra la Tortura. *Observación General N°2 “Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes”*. UN Doc. CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008, párr. 18.

¹⁰⁶ Comité contra la Tortura. *Caso Hajrizi Džemajil et al. v. Yugoslavia*, UN Doc. CAT/C/29/D/161/2000 de 2 de diciembre de 2002, párr. 9.2.

la Convención prevé expresamente la posibilidad de que los Estados establezcan definiciones más amplias.

96. Como cuestión final, cabe destacar que la interpretación reseñada ha sido seguida por las organizaciones de derechos humanos que se encargan de labores vinculadas a la prevención de la tortura. Por ejemplo, la Asociación para la Prevención de la Tortura (“APT”) ha señalado que los equipos que visitan y monitorean lugares de detención deben recordar que el deber del personal de custodia incluye la responsabilidad de proteger a los detenidos de los otros prisioneros, y que “[l]os actos de violencia cometidos entre los propios detenidos no deben ser ignorados”.¹⁰⁷ Asimismo, ella destaca que en muchos casos estos actos de violencia son tolerados por el personal.¹⁰⁸ Como ya veíamos, dicha tolerancia podría constituir una hipótesis de “*aquiescencia*”, que se encuentra prevista en la CAT.
97. La APT también ha indicado que “[n]o es el papel del visitador decidir si el tratamiento alegado constituye tortura” y que las denuncias de tortura o malos tratos deben transmitirse a las autoridades.¹⁰⁹ Ello confirma que no corresponde a los órganos de monitoreo realizar la calificación penal o confirmar que ella se adecúa perfectamente con el tipo para efectos de realizar la denuncia.
98. En suma, el análisis realizado confirma que la obligación de denuncia prevista en el artículo 10 de la Ley 21.154 aplica respecto de cualquier acto que cumpla con la definición de tortura de la letra a) del artículo 2, con independencia de quien sea el presunto autor de estos hechos, estando en cualquier caso las Expertas del Comité y su personal de apoyo obligados a denunciar esos actos ante el Ministerio Público. Lo anterior, con la limitación relativa al deber de confidencialidad y de obtención del consentimiento de la víctima, según se revisará en la sección siguiente.

IV. SOBRE LA TENSION ENTRE LA PROTECCION DE LA VICTIMA Y EL DEBER DE RESERVA, FRENTE AL DEBER DE DENUNCIAR

99. Como ya ha sido expuesto precedentemente, el Comité se encuentra exento de la obligación de denuncia de todos los funcionarios públicos, exceptuadas las hipótesis de riesgo vital o tortura, caso en el cual existirá el deber de denunciar.
100. Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede equilibrar dicho deber de denunciar con la protección de la víctima, en un escenario en que la denuncia puede resultar perjudicial para ésta y dejarla en una situación de mayor vulnerabilidad por el riesgo de eventuales las represalias.
101. A este respecto, si bien el artículo 10 dispone que los expertos y el personal de apoyo “deberán denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad o sean víctimas de alguno de los actos definidos como tortura en la letra a) del artículo 2”, como también remitir los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos a fin de que éste pueda deducir las acciones legales pertinentes, la norma también dispone que “[e]n la comunicación efectuada con motivo de una denuncia, prevalecerá la reserva de la información,

¹⁰⁷ APT, *Monitoreo de lugares de detención – una guía práctica*, Ginebra, 2004, p. 104.

¹⁰⁸ *Ibid*, p. 104.

¹⁰⁹ *Ibid*, p. 106.

en los términos dispuestos en el artículo siguiente, y la prohibición de hacer públicos datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada”.

102. Este artículo debe ser leído juntamente con el artículo 11 de la misma Ley 21.154, que indica:

“Artículo 11.- Reserva de la información. La información que recojan los expertos del Comité de Prevención contra la Tortura y el personal de apoyo ya sea con ocasión de las visitas periódicas o de las entrevistas que sostengan, tendrá carácter reservado, incluso respecto de los demás funcionarios del Instituto que no participen de las funciones de éste, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10. La violación de esta reserva dará origen a negligencia manifiesta e inexcusable de sus funciones de acuerdo con lo señalado en el artículo 5”.

103. Asimismo, el artículo 5 de la Ley —que regula la organización del Comité— hace referencia a los principios de su actuación, señalando:

“Artículo 5.- Integración. [...] En cumplimiento del Protocolo Facultativo, el Comité de Prevención contra la Tortura, en su organización, funcionamiento y ejercicio de funciones deberá regirse por los principios internacionales aplicables a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, tales como independencia de su personal, autonomía funcional, confidencialidad en sus actuaciones y reserva de la información obtenida en ejercicio de sus funciones”.

104. En consecuencia, en el contexto del trabajo que deberá desarrollar el Mecanismo Nacional, queda en evidencia la colisión de dos principios: (i) el deber de denunciar en ciertos casos calificados, y, (ii) el deber de reserva o confidencialidad, en la medida que no se cuente con el consentimiento de la víctima.

105. Con el propósito de abordar la tensión existente entre ambos principios, expondremos a continuación el tratamiento que inicialmente ha recibido este debate en nuestra legislación, para luego enfocar esta discusión desde la normativa y experiencia internacional.

A. Historia de la ley

106. La obligación de reserva prevista en la Ley 21.154 ya venía prevista en el proyecto de ley de la Presidenta Bachelet. En efecto, el Mensaje ya indicaba que, en resguardo de la confidencialidad de la información recopilada en las visitas y entrevistas, ésta tendría el carácter de reservada, incluso respecto de otras áreas de trabajo del Instituto,¹¹⁰ y mencionaba los principios de reserva y confidencialidad como uno de los rectores del trabajo del Comité.¹¹¹

107. A su vez, las disposiciones relevantes contenidas en el proyecto de ley eran los artículos 5, 11 y 12, que disponían:

¹¹⁰ Historia de la Ley, Mensaje, p. 6.

¹¹¹ *Ibid*, p. 10.

Artículo 5.- Integración. [...] El Comité deberá regirse por los principios de independencia de su personal, autonomía funcional, confidencialidad en sus actuaciones y reserva respecto de la información obtenida en ejercicio de sus funciones.

Artículo 11.- Excepción de denuncia. En el desarrollo de sus visitas preventivas y con el propósito de resguardar los fines del Comité, los expertos y expertas y el personal de apoyo del mismo no estarán obligados a denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, los expertos y expertas y el personal de apoyo deberán denunciar aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad. En la comunicación con motivo de una denuncia, prevalecerá la reserva de la información, en los términos dispuestos en el artículo siguiente, y la prohibición de hacer públicos datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

Artículo 12.- Reserva de la información. La información que recojan los expertos y expertas del Comité y el personal de apoyo ya sea con ocasión de las visitas periódicas o de las entrevistas que sostengan, tendrá carácter reservado, incluso respecto de los demás funcionarios y funcionarias del Instituto que no participan de las funciones de este, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 11. La violación de esta reserva dará origen a negligencia manifiesta e inexcusable de sus funciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 5.¹¹²

108. De la simple lectura del articulado original, resulta bastante claro que la denuncia a ser por los expertos y personal de apoyo en los casos de riesgo vital –y luego también en los casos de tortura– debe regirse por el deber de reserva, no pudiendo entregarse los datos personales de la persona interesada sin su consentimiento. Lo anterior supondría realizar una denuncia sin identificación de la víctima, en caso de no contar con su aprobación.
109. Sin embargo, en el marco de la tramitación legislativa, no existió un gran debate sobre el alcance de esta obligación de reserva. Por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos hizo una referencia general a la confidencialidad y el deber de reserva de los miembros del Comité, incluyendo la información recogida con ocasión de las visitas.¹¹³ Por su parte, la Directora de la Oficina Regional para América Latina de la Asociación de Prevención contra la Tortura (“APT”) se refirió al artículo 5 del proyecto, indicando respecto del principio de confidencialidad, que este no rige siempre respecto de las actuaciones del Mecanismo, ya que sus informes y recomendaciones si son públicas, debiendo dejarse dicha determinación a criterio del propio mecanismo.¹¹⁴ Por su parte, respecto al deber de reserva, indicó que el Protocolo Facultativo entiende por información reservada “*aquella referida a casos individuales*”, y que ella tiene por objeto la protección de las personas y la promoción

¹¹² *Ibid*, p. 11.

¹¹³ Historia de la Ley, Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, p. 28. Ver también Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, p. 71.

¹¹⁴ Historia de la Ley, Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, p. 31

de un diálogo constructivo, y que en consecuencia “*debe tratarse de una herramienta facultativa y discrecional del MNP, y no una metodología imperativa*”.¹¹⁵

110. Por su parte, el coordinador del Observatorio para el cierre de las Escuelas de las Américas (SOA Watch) indicó que, en casos de situaciones graves de tortura, los expertos deberían informar reservadamente mediante oficio al Ministerio Público.¹¹⁶ El mismo reiteró más adelante que si hubiera evidencia de personas sometidas a tortura o tratos degradantes “*deberán hacer la denuncia de manera reservada para perseguir el castigo que corresponde*”.¹¹⁷
111. Finalmente, en el marco de la discusión en Sala en el Senado existieron dos breves referencias a este punto. Por una parte, el Senador Latorre hizo referencia al Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile entre 2014 y 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y destacó el hecho de que existirían malos tratos al interior de las cárceles pero que no existiría confidencialidad para la interposición de denuncias por posibles abusos cometidos.¹¹⁸ Por su parte, la senadora Allende hizo referencia al hecho de que, en muchos casos, la violencia al interior de los recintos penitenciarios y policiales es invisibilizada al no ser denunciada por medio a represalias que tienen las personas privadas de libertad, y destacó el hecho de que el mecanismo asegura la reserva y confidencialidad de la información.¹¹⁹
112. Si bien existieron otras referencias generales al deber de reserva previsto en el proyecto de ley y algunas modificaciones a la redacción de los artículos precedentes, no existió mayor discusión sobre la relación entre el deber de denuncia de los miembros del Mecanismo y esta obligación de reserva. Sin embargo, estas breves referencias al trámite legislativo demuestran la importancia de este deber de reserva y confidencialidad, pues tendría como objeto proteger a las personas privadas de libertad.

B. Reglas aplicables de otros organismos de Derechos Humanos de nuestro país

113. A fin de examinar el alcance del deber de reserva, puede ser pertinente examinar los estándares aplicables a otros órganos de derechos humanos del país.
114. Sobre este punto, la Ley 20.405 “Instituto Nacional de Derechos Humanos” no contiene disposiciones sobre reserva o confidencialidad de la información obtenida por sus funcionarios. Por el contrario, el artículo 5 de la Ley 20.405 dispone:

“Artículo 5º.- Todos los actos y resoluciones del Instituto, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, serán públicos, exceptuando aquella información que en virtud del artículo 8º de la Constitución Política tenga el carácter de reservado o secreto. El Instituto se regirá por las normas de la ley sobre acceso a la información pública”.

¹¹⁵ *Ibid*, p. 31

¹¹⁶ *Ibid*, p. 37.

¹¹⁷ *Ibid*, p. 39.

¹¹⁸ Historia de la Ley, Discusión en Sala, Senado, pp. 131-132.

¹¹⁹ *Ibid*, p. 141.

115. La única norma que establece reserva de información es el artículo 3 transitorio de la misma Ley, que hace referencia a la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, respecto de la cual se establece que sus actuaciones y los antecedentes recibidos tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.
116. Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuenta con un Protocolos sobre esta materia.
117. En términos generales, la Pauta de Visita a Cárceles del Instituto¹²⁰ hace referencia a los principios de no causar daño y respetar la confidencialidad de la información proporcionada,¹²¹ y establece un procedimiento que sigue los lineamientos del Protocolo de Estambul, al que ya nos referiremos en mayor detalle. En materia de reserva y confidencialidad, la Pauta indica expresamente que la denuncia y otras acciones judiciales pueden realizarse sólo si se cuenta con el consentimiento de la persona involucrada.¹²²
118. Ahora bien, el INDH también cuenta con un Protocolo de Intervención Judicial específico para una Misión de Observación del SENAME.¹²³ En dicho documento se da cuenta de ciertos criterios de confidencialidad respecto de mecanismos de queja y denuncia por parte de niños, niñas y adolescentes acogidos en una residencia de protección. Si bien dicho documento establece ciertos criterios para proteger la privacidad del NNA y el carácter confidencial de las comunicaciones, como también medidas que deben tomarse para evitar todo tipo de represalias, el Protocolo de todas maneras establece ciertos límites a la confidencialidad la que califica como relativa, en tanto cede en la medida que haya un interés superior, como la protección del NNA.¹²⁴ Al respecto, se indica que en ciertos casos de riesgo vital (que ejemplifica como amenazas de homicidio, maltrato infantil, abuso sexual infantil), el entrevistador se verá en la obligación de comunicarlas a las autoridades correspondientes.¹²⁵
119. Por su parte, en su Informe 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el marco del trabajo de recepción de denuncias electrónicas vinculadas con casos de violación a los derechos humanos ocurridas con posterioridad al 18 de octubre del mismo año, señala que en dicha labor “[s]e cautelo la confidencialidad de las víctimas, su consentimiento para el desarrollo de acciones de denuncia ante tribunales o medios de comunicación”.¹²⁶

¹²⁰ Instituto Nacional de Derechos Humanos, *Pauta de Visita a Cárceles u Otros Centros de Privación de Libertad ante casos de Denuncias Particulares*, s/f.

¹²¹ *Ibid*, pp. 2-3.

¹²² *Ibid*, p. 9.

¹²³ Instituto Nacional de Derechos Humanos, Protocolo de Intervención Judicial del INDH, Misión de Observación SENAME. Disponible en: <https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2018/03/Protocolo-de-intervencion-judicial.pdf>.

¹²⁴ *Ibid*, p. 15.

¹²⁵ *Ibid*, p. 16.

¹²⁶ Instituto Nacional de Derechos Humanos, *Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile en el contexto de la crisis social*, 17 Octubre - 30 Noviembre 2019, p. 111.

120. En un sentido similar, cabe destacar que el Consejo para la Transparencia, mediante resolución de fecha 06 de marzo de 2020, en causa de amparo rol C1216-20, decidió respecto de una solicitud de acceso a información pública que buscaba obtener “(...) *el nombre de las víctimas en relación a la lista de denuncias por vulneraciones a los derechos humanos y los respectivos relatos de dichas víctimas, recibidos entre el 10 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2020*”, valorando el carácter de reserva que el Instituto Nacional de Derechos Humanos esgrimió para negar la entrega de dicha información.¹²⁷
121. En dicha resolución, el Consejo para la Transparencia, fundó esta decisión en la necesidad de proteger los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, señalando que “(...) *la naturaleza del contenido de las denuncias cuya identificación se solicita, versan sobre vulneraciones a los derechos humanos, calificadas por el INDH como diversos tipos de tortura o apremios ilegítimos ejercidos por agentes del Estado durante un período determinado (octubre de 2019 a enero de 2020), vinculadas especialmente a información referida al estado de salud físico o psíquico de las víctimas involucradas. Por lo anterior, se verifica en la especie que la publicidad del nombre de denunciantes y víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, y sus respectivos relatos, al tratarse de datos personales y eventualmente, datos sensibles de éstas, producirá afectación a la vida privada de las personas en los términos expuestos por la reclamada. Por lo expuesto, respecto de dicha materia se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia*”.¹²⁸
122. Asimismo, en la referida resolución, el Consejo funda su decisión también en la necesidad de resguardar la confianza que las víctimas entregan al Instituto Nacional de Derechos Humanos al momento de denunciar la ocurrencia de este tipo de hechos. En este sentido, la resolución expresa que “(...) *teniendo presente las facultades legales que asigna la ley a la entidad en materia de protección de los derechos humanos, existe un doble reforzamiento del deber de reserva de la identidad de las presuntas víctimas, lo que implica no sólo la confidencialidad respecto de su nombre y sus relatos. En esta línea de razonamiento, la confidencialidad de la identidad y otros datos sensibles de los afectados, se vuelve un imperativo para el órgano en el debido cumplimiento de su función de protección de los derechos humanos que le asigna la ley, y cabe resguardar la identidad de los denunciantes, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, en este caso, el INDH ejerza las acciones legales que mandata el citado texto legal. Por lo expuesto, también se configura respecto de la información analizada la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia*”.¹²⁹
123. En consecuencia, la normativa y práctica del INDH parece ser el de mantener la reserva de la información de los denunciantes salvo que cuente con su consentimiento para divulgarla, aunque ello tiene como limitación el caso de vulneraciones a NNA, en que el Instituto ha indicado que la confidencialidad cede en beneficio de su interés superior, que obliga al funcionario a cargo a informar a las autoridades en casos de riesgo vital.

¹²⁷ Consejo Para la Transparencia, Decisión de amparo Rol C1216-20, 06 de marzo de 2020. Disponible en: https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW/Archivos/C1216-20/DecisionWeb_C1216-20.pdf.

¹²⁸ *Ibid*, Considerando 6.

¹²⁹ *Ibid*.

124. En segundo lugar, la Ley 21.067 que “Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez”, en su artículo 8 de la Ley dispone:

Artículo 8°.- La información y antecedentes recibidos por la Defensoría no podrán ser empleados para fines ajenos al ámbito de sus competencias. Su tratamiento deberá siempre respetar los derechos y las garantías constitucionales y legales, especialmente lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

125. De esta forma, todos los actos y resoluciones de la Defensoría de la Niñez, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, serán públicos, exceptuando aquella información que diga relación con el ámbito de protección de la ley N° 19.268, que protege la vida privada de las personas y el artículo 8° de la Constitución Política de la República. En lo demás, la Defensoría estará sujeta a las normas de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. Sin embargo, no tenemos conocimiento si la Defensoría de la Niñez cuenta con protocolos de actuación vinculado a deberes de reserva y/o obligaciones de denuncia en términos similares a aquellos que hemos examinado en el caso del INDH.

126. En cualquier caso, en el área de la protección de niñas, niños y adolescentes, la Ley N° 20.032, que establece el “Sistema de Atención a la Niñez y la Adolescencia”, en su artículo 14, consigna un deber absoluto de denuncia ante el Tribunal competente, de hechos que configuren la vulneración de derechos de NNA, respecto de personas responsables de proyectos educacionales vinculados con la ley y de profesionales que dan atención directa a este grupo de personas. En caso de no constituir delito los hechos objeto de la denuncia, la ley faculta al Tribunal competente para que adopte las medidas judiciales que sean necesarias en favor del niño, niña o adolescente. Ello también demostraría que existiría un especial deber de denuncia respecto de vulneraciones NNA, que en principio pareciera tener primacía por sobre los deberes de confidencialidad.

127. Por otra parte, en relación con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar, debemos tener presente el Decreto N° 355 de la Subsecretaría del Interior, de fecha 25 de abril de 1990, que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Dicho Decreto, junto con establecer reglas de reserva sobre el funcionamiento de la referida Comisión y la protección de identidad de testigos, en su artículo segundo indica “(...) si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que corresponda”.

128. Sobre este mismo punto, los artículos 7 y 8 del mencionado Decreto, establecen:

Artículo 7°: La Comisión dictará su propio reglamento interno para regular su funcionamiento. Las actuaciones de la Comisión se realizarán en forma reservada.

El reglamento determinará las actuaciones que la Comisión podrá delegar en uno o más de sus miembros, o en el Secretario.

Artículo 8°: De oficio o a petición de parte, la Comisión podrá tomar medidas para guardar la identidad de quienes le proporcionen información o colaboren en sus tareas.

Las autoridades y servicios de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la colaboración que ella les solicite, poner a su disposición los documentos que les requiera y facilitar su acceso a los lugares que ella estime necesario visitar.

129. Como se puede apreciar, la normativa vinculada con otros organismos de la administración del Estado que se desempeñan en el área de los Derechos Humanos, establece, en términos generales, limitaciones al acceso a la información pública con el objeto de resguardar a las personas que, en el marco de las facultades legales que la normativa les provee, han aportado información para el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, pareciera que dicho deber de reserva o confidencialidad no es absoluto al menos respecto de posibles vulneraciones a NNA.

C. Otros organismos nacionales

130. Una experiencia que es necesario resaltar, en relación con la tensión existente entre el deber de denunciar y la protección de los derechos de las víctimas, es la del Colegio Médico de Chile. Esta organización gremial, con fecha 24 de octubre de 2019, estableció el protocolo de denuncias para informes de lesiones en el marco de Derechos Humanos. En dicho documento, junto con promover la denuncia de situaciones de vulneración de Derechos Humanos, se plantea como requerimiento mínimo de la denuncia en cuestión, la obtención del consentimiento informado de la víctima o de su responsable legal, en caso de los menores de edad, Dicho consentimiento alcanza el relato de los hechos a denunciar, los antecedentes clínicos que la persona pueda aportar o el levantamiento de pruebas tendientes a la constatación de las lesiones de la víctima¹³⁰.
131. Esta acción del Colegio Médico de Chile se enmarca, entre otras resoluciones, en aquella adoptada por la Asociación Médica Mundial en el año 1990, en la que se solicita a todas las asociaciones médicas nacionales que examinen la situación de los derechos humanos en sus propios países y se aseguren de que los médicos no oculten pruebas, por mucho que teman a las represalias¹³¹.
132. Considerando lo expuesto respecto del consentimiento informado, conviene tener presente que el artículo 4° de la Ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud”, señala respecto de este concepto que “[t]oda persona o quien la represente tiene derecho a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso, independientemente de la magnitud de los daños que aquel haya ocasionado”.

¹³⁰ Colegio Médico de Chile, “Protocolo de denuncias para informes de lesiones en el marco de Derechos Humanos”, de 24 de octubre de 2019, disponible en: <http://www.colegiomedico.cl/protocolo-de-denuncia-para-informes-medicos-de-lesiones-en-el-marco-de-los-derechos-humanos/>.

¹³¹ Protocolo de Estambul, párr. 55. Versión disponible en “Instrumentos Internacionales para la Prevención y Sanción de la Tortura”, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Buenos Aires, Argentina, 2006. Disponible en: https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/instrumentos_internacionales_para_la_prevenccion_y_sancion_de_la_tortura_0.pdf.

133. Asimismo, el artículo 5° de la referida Ley, en relación con el derecho a la vida privada de los pacientes, establece que los prestadores de servicios de salud deberán “[r]espeter y proteger la vida privada y la honra de la persona durante su atención de salud. En especial, se deberá asegurar estos derechos en relación con la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, cualquiera que sea su fin o uso. En todo caso, para la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones para usos o fines periodísticos o publicitarios se requerirá autorización escrita del paciente o de su representante legal”.
134. Lo anterior también va en la línea de lo dispuesto en el Protocolo de Estambul, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que complementa el contenido y alcance de nuestra legislación en lo relativo al consentimiento informado, señalando: “[Un] precepto absolutamente fundamental de la ética médica moderna es que los propios pacientes son los mejores jueces de sus propios intereses. Esto requiere que los profesionales de la salud den prioridad normalmente a los deseos de un paciente adulto y competente y no a la opinión de cualquier persona con autoridad acerca de qué sería lo mejor para esa persona. (...) La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial especifica que, antes de todo examen o procedimiento, el médico tiene la obligación de obtener el consentimiento voluntario e informado de los pacientes mentalmente competentes. Esto significa que los sujetos necesitan conocer las consecuencias que puede tener su consentimiento y su rechazo”.¹³²
135. De esta forma, la idea del consentimiento informado, en cuanto criterio ético profesional de los médicos, plasmado y reconocido legalmente por nuestra legislación, aparece como un punto de equilibrio adecuado respecto de la tensión de los principios que hemos identificado anteriormente. En efecto, el mismo no sólo entrega una directriz clara para los profesionales de la salud que constantemente se ven enfrentados a casos que pueden configurar tortura, sino que además, constituye un punto de partida conductual necesario para asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

D. Estándares internacionales

136. El artículo 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes reconoce el derecho de toda persona que alegue haber sido sometida a tortura de presentar una queja, a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por las autoridades competentes, tomándose medidas “para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado”. No obstante lo anterior, el Comité contra la Tortura, de conformidad al artículo 22 de la referida Convención y en el marco de las comunicaciones que recibe de personas sometidas a su jurisdicción que aleguen la vulneración de sus derechos por parte del Estado, no acepta el anonimato en la presentación de este tipo de denuncias.
137. Por su parte, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura también contiene disposiciones relevantes sobre este punto, incluyendo en el artículo 2.3 que el Subcomité para la Prevención de la Tortura se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad.

¹³² *Ibíd*, párr. 62 y 63.

138. A su vez, el párrafo 1 del artículo 21 del mismo Protocolo Facultativo prohíbe todo tipo de sanción contra una persona u organización por haber comunicado cualquier información al Mecanismo Nacional de Prevención, enfatizándose así el deber de protección a los denunciantes. Luego, el párrafo 2 del mismo artículo hace referencia a la información confidencial recogida por los Mecanismos Nacionales de Prevención, indicando en su artículo 21 que ella “*tendrá carácter reservado*”, señalando además que “[n]o podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada”.
139. La necesidad de resguardar la reserva de la información y así evitar todo tipo de represalias contra las personas privadas de libertad ha sido desarrollada en mayor detalle por el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Por ejemplo, en 2016 el Subcomité publicó un documento de Política relativo a las represalias que resulta interesante considerar.¹³³ Dicho documento define represalias como “*los actos u omisiones que puedan atribuirse a autoridades o funcionarios de un Estado parte que realicen, permitan o toleren ‘sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado al Subcomité para la Prevención o a sus miembros cualquier información, ya sea verdadera o falsa’*”.¹³⁴ Si bien dicho documento hace referencia a las represalias en el marco del análisis del artículo 15 del Protocolo Facultativo, su análisis es igualmente aplicable al caso de posibles represalias que puedan generarse por envíos de información al Comité, puesto que enfatiza la idea básica de protección de las víctimas, denunciantes y testigos contra malos tratos o intimidación por cooperar o tratar de cooperar.¹³⁵
140. A este respecto, el documento indica que al Subcomité le corresponde garantizar que la situación de las personas con las que se relaciona no resulte perjudicada, a efectos de cumplir con su mandato preventivo y el imperativo básico “*no dañar*”.¹³⁶ Por lo mismo, señala que la política para evitar represalias debe tenerse en cuenta en todas las actividades, y en particular en la preparación de una visita, en el transcurso de ésta y con posterioridad a la misma,¹³⁷ como también en los métodos de trabajo.¹³⁸ Asimismo, el documento hace referencia al principio de confidencialidad al momento de aplicar la política sobre represalias,¹³⁹ lo que reafirma la obligación de confidencialidad que tiene también el Mecanismo bajo la ley chilena.

¹³³ Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. *Política del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sobre las represalias en relación con las visitas previstas en su mandato*, 31 de mayo de 2016 (UN Doc. CAT/OP/6/Rev.1).

¹³⁴ *Ibid.*, p. 2, párr. 1. Otro documento que hace referencia a las represalias y que pueden ser relevantes para el trabajo del Mecanismo son la Resolución 68/268 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 9 de abril de 2014, que condenó todos los actos de intimidación y represalias contra individuos y grupos por su contribución a la labor de los órganos de tratados de derechos humanos, e instó a los Estados a adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir y eliminar tales violaciones a los derechos humanos.

¹³⁵ *Ibid.*, p. 2, párr. 2.

¹³⁶ *Ibid.*, p. 2, párr. 3.

¹³⁷ *Ibid.*, p. 2, párr. 5.

¹³⁸ *Ibid.*, p. 2, párr. 6.

¹³⁹ *Ibid.*, p. 2, párr. 7.

141. Otro documento relevante son las Directrices contra la Intimidación o las Represalias (“Directrices de San José”), que de hecho aparecen también citadas en el Documento de Política elaborado por el Subcomité.¹⁴⁰ En dicho documento se establecen directrices sobre el deber del Estado de proteger a los individuos de todo tipo de actos de intimidación o represalias, que incluyen referencia a los principios de “no hacer daño”, confidencialidad y consentimiento libre e informado.¹⁴¹
142. Si bien, al igual que en el caso del Subcomité para la Prevención de la Tortura, las Directrices hacen referencia a una serie de buenas prácticas y procedimientos que escapan de los alcances de este análisis, cabe destacar que dentro de las medidas preventivas se hace referencia a que los órganos deben permitir peticiones de personas o grupos para proporcionar información de manera confidencial.¹⁴² Asimismo, dichas Directrices hacen referencia al deber del órgano pertinente de obtener el consentimiento de la persona o grupo afectado antes de ponerse en contacto con el Estado para obtener más información o expresar su preocupación por actos de represalias.¹⁴³ En ese sentido, las Directrices confirman la importancia del principio general de confidencialidad y reserva en las actuaciones.
143. Otra norma que puede ser relevante para este análisis, y que se refiere específicamente a las personas privadas de libertad, es el Principio 29 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión¹⁴⁴ que indica que las personas detenidas o presas tendrán el derecho “a comunicarse libremente y en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los lugares de detención o prisión”. Nuevamente entonces, la idea de confidencialidad absoluta queda reforzada.
144. El ya citado Protocolo de Estambul, aparece como otra fuente de estándares vinculados al principio de confidencialidad y a la protección de la víctima. Desde una perspectiva interdisciplinaria, el Protocolo referido hace referencia a la idea de confidencialidad y al evidente dilema ético, objeto del análisis que estamos desarrollando en esta sección de este trabajo. A este respecto el Protocolo de Estambul reconoce sobre el deber de confidencialidad y la protección del paciente en los siguientes términos:

“[E]n ciertas jurisdicciones, la obligación de secreto profesional se considera tan importante que se ha incorporado a la legislación nacional. El deber de confidencialidad no es absoluto y se puede incumplir éticamente en circunstancias excepcionales cuando el no hacerlo podría previsiblemente provocar graves daños a personas o graves perturbaciones a la justicia. Pero, en general, el deber de confidencialidad referido a información sanitaria personal identificable sólo puede soslayarse con el permiso informado del paciente (...). El dilema se plantea cuando el profesional de la salud se ve presionado o requerido por la ley para que revele información

¹⁴⁰ Organización de Naciones Unidas, *Directrices contra la Intimidación o Represalias* (27° reunión de Presidentes de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos), 30 de julio de 2015 (UN Doc. HRI/MC/2015/6).

¹⁴¹ *Ibid*, párr. 5(e)

¹⁴² *Ibid*, párr. 18.

¹⁴³ *Ibid*, párr. 21.

¹⁴⁴ Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988

identificable que probablemente va a poner en peligro a un paciente. En esos casos prima la obligación ética fundamental de respetar la autonomía y los mejores intereses del paciente, así como hacer el bien y evitar dañarle. Esta obligación prima sobre todas las demás consideraciones”.¹⁴⁵ [Énfasis agregado]

145. En esta dirección, el Protocolo de Estambul reconoce que los profesionales de salud se ven constantemente confrontados con un dilema de dualidad de obligaciones, por cuanto, por una parte, tienen una obligación con su paciente de promover los mejores intereses para su persona, y por otro, tienen una obligación general ante la sociedad de asegurar el triunfo de la justicia y prevenir violaciones a los derechos humanos¹⁴⁶. Sobre esto, el Protocolo dispone: “[E]n esos casos, el profesional de la salud deberá negarse a cumplir una ley o un reglamento en lugar de comprometer los preceptos básicos o exponer a sus pacientes a un grave peligro”.¹⁴⁷ Luego, en el contexto de este dilema ético que venimos desarrollando, señala: “[E]l principio fundamental de evitar daño debe figurar en primer plano cuando se presenten esos dilemas. El profesional de la salud deberá buscar soluciones que promuevan la justicia sin violar el derecho de confidencialidad que asiste al individuo. Se buscará consejo junto a organismos de confianza; en ciertos casos, puede tratarse de la asociación médica nacional o de organismos no gubernamentales. Otra posibilidad es que, con apoyo y aliento, algunos pacientes reacios lleguen a acceder a que el asunto se revele dentro de límites acordados”¹⁴⁸.
146. En definitiva, el Protocolo de Estambul plantea este dilema que venimos desarrollando como un constante contrapeso de circunstancias, donde siempre la toma de decisión implicara privilegiar un interés en detrimento de otro. En ese sentido, el Protocolo desarrolla: “Cuando los prisioneros están de acuerdo en la revelación, no existe ningún conflicto y hay una evidente obligación moral. Pero si el recluso se niega a permitir que se revele el hecho, el médico debe ponderar el riesgo y el peligro potencial para ese paciente concreto contra los beneficios que para la población penitenciaria en general y para los intereses de la sociedad puede reportar el prevenir que se perpetúen esos abusos”.¹⁴⁹
147. Al mismo tiempo, el Protocolo también reconoce dentro de los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura, el deber del Estado de proteger a la víctima o denunciante de este tipo de hechos, cuando señala que “[l]as presuntas víctimas de torturas o malos tratos, los testigos, quienes realicen la investigación, así como sus familias, serán protegidos de actos o de amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que pueda surgir a resultas de la investigación. Los presuntos implicados en torturas o malos tratos serán apartados de todos los puestos

¹⁴⁵ Protocolo de Estambul, párr. 64. Versión disponible en “Instrumentos Internacionales para la Prevención y Sanción de la Tortura”, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Buenos Aires, Argentina, 2006. Disponible en: https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/instrumentos_internacionales_para_la_prevenccion_y_sancion_de_la_tortura_0.pdf.

¹⁴⁶ *Ibid*, párr. 66.

¹⁴⁷ *Ibid*, párr. 67.

¹⁴⁸ *Ibid*, párr. 68.

¹⁴⁹ *Ibid*, párr. 71.

- que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los querellantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las investigaciones”*.¹⁵⁰
148. En otras palabras, pero esta vez en relación con la entrevista de la presunta víctima y de otros testigos, el referido Protocolo insiste en reconocer que “[e]l Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas de la tortura, los testigos y sus familias de toda violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación que pueda producirse en el curso de la investigación. Los investigadores informarán a los testigos sobre las consecuencias que puede tener el que formen parte de la investigación y también sobre cualquier otra cosa que pudiera pasar en relación con el caso y que pudiera afectarles”.¹⁵¹
149. Por último, no está demás señalar, que el Protocolo de Estambul razona respecto de la priorización de los intereses contrapuestos que concurren en la tensión que hemos expuesto, concluyendo en el marco de la investigación de hechos que puedan constituir tortura que “[c]uando parezca probable que los testigos vayan a verse en peligro a causa de su testimonio, el investigador tratará de hallar otras fuentes de información”.¹⁵²
150. Otro documento que puede ser interesante a efectos de examinar este dilema es el *Manual on Human Rights Monitoring* (el “Manual de Monitoreo”) elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos elaboró el. Dicho documento también da cuenta de los desafíos relativos a la confidencialidad y la importancia de contar con la autorización de las posibles víctimas o testigos involucrados. Si bien dicho documento está principalmente dirigido a personas que trabajan para dicha oficina, la metodología y lineamientos establecidos son igualmente aplicables al rol de instituciones nacionales de protección de los derechos humanos, como este mismo reconoce.¹⁵³
151. En términos generales, el documento reconoce la aplicabilidad de varios principios en la labor de monitoreo: (1) el principio de no dañar, indicando que este requiere, como mínimo, que “la acción o inacción de los oficiales de derechos humanos no debe poner en peligro la seguridad de las víctimas, testigos u otras personas con quienes entren en contacto”;¹⁵⁴ el principio de la confidencialidad, con el objeto de proteger la seguridad de las víctimas, testigos y otras personas que están cooperando,¹⁵⁵ y respecto del cual indica que tiene primacía por sobre otras consideraciones¹⁵⁶ (incluso la persecución penal de autores de violaciones a los derechos humanos); y el principio del consentimiento informado para usar y compartir la información entregada, el que debe además ser específico.¹⁵⁷ A mayor abundamiento, el Manual indica que incluso en casos en que se obtenga el consentimiento, el oficial a cargo deberá evaluar las posibles implicancias, y no deberá revelarse la información si hay un

¹⁵⁰ *Ibid*, párr. 79.

¹⁵¹ *Ibid*, párr. 87.

¹⁵² *Ibid*, párr. 95.

¹⁵³ Office of the High Commissioner for Human Rights, *Manual on Human Rights Monitoring*, Introduction, 2011 p. VI.

¹⁵⁴ *Ibid*, Capítulo 2, p. 4. (Traducción libre, original en inglés).

¹⁵⁵ *Ibid*, Capítulo 2, p. 6.

¹⁵⁶ *Ibid*, Capítulo 2, p. 6. Ver también Capítulo 14, p. 8.

¹⁵⁷ *Ibid*, Capítulo 2, p. 7.

- riesgo de generar daño, o entregar la información de una manera que remueva el riesgo (por ejemplo, sin entregar detalles específicas).¹⁵⁸
152. Atendidos los especiales desafíos que presenta, el Manual contiene un capítulo que trata específicamente sobre la protección de víctimas, testigos y otras personas que cooperan. En esa sección se vuelve a reiterar la importancia del principio de confidencialidad, que incluye tanto la identidad de la persona que coopera como la información entregada, “*a menos que se haya dado un consentimiento específico para su uso*”,¹⁵⁹ incluyendo para informar a las autoridades competentes.¹⁶⁰ Asimismo, el Manual enfatiza que la persona debe estar plenamente consciente de las potenciales implicancias que ello puede tener en su seguridad y bienestar.¹⁶¹
153. Dicha sección también vuelve a hacer referencia al principio de no dañar, señalando que los oficiales de derechos humanos “*tienen la obligación de no poner en peligro la vida, la seguridad, la libertad y el bienestar de las víctimas, testigos y otras personas colaboradoras*”.¹⁶²
154. En el caso particular de los centros de privación de libertad, el Manual indica que en caso que un recluso exprese preocupaciones relativas a derechos humanos en una entrevista privada, los oficiales no deberán revelarlo públicamente “*a menos que el recluso haya dado su consentimiento y sea estratégicamente oportuno hacerlo*”.¹⁶³ Si bien el Manual prevé la existencia de un capítulo específico sobre visita a centros de detención, el mismo no se encuentra aún disponible, pues continúa en proceso de elaboración.¹⁶⁴ Sin embargo, la versión anterior del Manual, correspondiente al año 2001¹⁶⁵ si contiene dicha sección sobre visitas a personas detenidas (que se encuentra en proceso de actualización). Si bien el mismo no examina en detalle el alcance del deber de confidencialidad y el consentimiento informado, el mismo si enfatiza que las entrevistas con el detenido deben tener carácter confidencial, y que deben darse seguridades al detenido de que es una fuente anónima, a menos que quiera que se identifiquen sus problemas y los oficiales de derechos humanos consideren improbable que sufra represalias.¹⁶⁶

¹⁵⁸ *Ibid*, Capítulo 2, p. 7. Ver también Capítulo 14, p. 7.

¹⁵⁹ *Ibid*, Capítulo 14, p. 7 (Traducción libre, original en inglés).

¹⁶⁰ *Ibid*, Capítulo 14, p. 7

¹⁶¹ *Ibid*, Capítulo 14, p. 7

¹⁶² *Ibid*, Capítulo 14, p. 8. (Traducción libre, original en inglés).

¹⁶³ *Ibid*, Capítulo 14, p. 19. (Traducción libre, original en inglés). Ver también Association for the Prevention of Torture, *Cuadernillo N°2*, Selección de las personas susceptibles de ser entrevistadas en el contexto del monitoreo preventivo de los lugares de detención (2009), p. 6: “*Además, inmediatamente después de haber obtenido información importante durante una entrevista privada, el equipo no debe de ningún modo revelar o comunicar dicha información a menos que cuente con el permiso del entrevistado en cuestión y que lo considere estratégicamente oportuno*”.

¹⁶⁴ Los capítulos que ya están actualizados se encuentran disponibles en la siguiente página: <https://searchlibrary.ohchr.org/record/4835>.

¹⁶⁵ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Manual de Capacitación para la fiscalización de los derechos humanos*. Serie de Capacitación Profesional N°7 (2001).

¹⁶⁶ *Ibid*, p. 156, para. 75.

155. Por otra parte, la Asociación para la Prevención de la Tortura, en el documento denominado “Prevención de la Tortura, Guía Operacional para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”, también reconoce los principios de “no hacer daño” y “respetar la confidencialidad”, como dos de los principios básicos de la vigilancia que las instituciones nacionales de Derechos Humanos deben realizar respecto de recintos de privación de libertad. Respecto del primero de ellos, la referida Asociación, ha señalado que *“[l]as personas privadas de su libertad son particularmente vulnerables y su seguridad debería ser siempre una consideración básica. Los equipos encargados de la visita no deben adoptar medida alguna que pueda poner en peligro a una persona o a un grupo. Las visitas mal planificadas – o las que no sigan unos principios y metodología básicos – podrían tener un efecto más negativo que positivo”*.¹⁶⁷ Por otra parte, el documento individualizado describe el principio de respeto de la confidencialidad, señalando que *“[e]s fundamental que todos los miembros del equipo encargado de la visita, incluidos los intérpretes, respeten la confidencialidad de la información facilitada por los detenidos durante las entrevistas privadas. No se debe hacer pública ninguna información sin el consentimiento expreso del detenido”*.¹⁶⁸
156. Por su parte, en un documento vinculado con el monitoreo de lugares de detención, la misma APT, respecto del manejo de las denuncias de tortura, ha señalado que *“Las denuncias de tortura o malos tratos deben transmitirse a las autoridades (administrativas y penales) responsables de investigar, con las precauciones relativas a las acciones realizadas a nombre de individuos, y siguiendo un procedimiento que no ponga en peligro a la persona afectada por la denuncia. La carga de la prueba, esto es, la responsabilidad para establecer la veracidad de la denuncia por medio de una investigación apropiada, recae en las autoridades competentes, no en la presunta víctima”*.¹⁶⁹
157. Asimismo, desde una perspectiva más práctica, la Asociación para la Prevención Tortura, ha señalado en relación con la falta de protección de las víctimas o potenciales denunciantes que *“una mirada integral a las represalias es el enfoque más apropiado, empezando por el principio clave de “no provocar daño”*”¹⁷⁰. En este sentido, la Asociación en el documento “Prevenir la Tortura: una responsabilidad compartida”, sugiere una serie de medidas, que apuntan a materializar el principio de no provocar daño en el contexto del desarrollo de labores de monitoreo, entre ellas, *“[A]segurar que las entrevistas se desarrollen en privado y sin testigos; Pedir consentimiento informado para revelar detalles personales; Entrevistar a un gran número de detenidos y/o detenidas para evitar el seguimiento de la información; Mantener un registro de todas las personas entrevistadas para poder realizar seguimientos en etapas posteriores; Ser cuidadoso y no plantear problemáticas en la conversación final con las autoridades de la institución; y Dar los datos de contacto de la institución de monitoreo en caso de cualquier duda”*.¹⁷¹

¹⁶⁷ Asociación para la Prevención de la Tortura, *Prevención de la tortura: Guía operacional para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos*, Mayo de 2010, p. 89. Disponible en: https://www.ohchr.org/documents/publications/preventingtorture_sp.pdf.

¹⁶⁸ *Ibid*, p. 89.

¹⁶⁹ Asociación para la Prevención de la Tortura, *Monitoreo de Lugares de Detención, una guía práctica*, diciembre de 2004, p. 106.

¹⁷⁰ Asociación para la Prevención de la Tortura, *Prevenir la Tortura: una responsabilidad compartida*, Foro Regional sobre el OPCAT en América Latina, 2014, p. 87.

¹⁷¹ *Ibid*, p. 88.

E. Experiencia internacional comparada de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura

158. Finalmente, resulta pertinente examinar algunos ejemplos de la práctica de otros Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura que han tenido que lidiar con cuestiones vinculadas al deber de confidencialidad y reserva de la información entregada en las visitas.
159. En el caso de Ecuador, el Protocolo de Visitas de la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes de la Defensoría del Pueblo, establece en su artículo 3 los principios sobre los cuales se basarán las visitas a recintos de privación de libertad. Entre ellos, se establecen:

“(...) 2. Respeto: Las y los miembros del MNPT se comprometen a respetar tanto a las personas privadas de libertad, sobre todo teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, al personal que labora en los lugares de privación de libertad y a las y los demás miembros del MNPT, en cuanto a su dignidad, diferencias individuales, culturales, género, etnia, religión, ideología, orientación sexual, privacidad, confidencialidad, condición socioeconómica, entre otros”. (...)

4. Independencia: Las y los miembros del MNPT, en ejercicio de sus funciones, evitarán influencias o presiones personales y/o institucionales que atenten contra su conformación ética, el respeto por las personas objeto de su ejercicio profesional y el cumplimiento de las directrices de la presente resolución.

5. Honestidad y honradez: Las y los miembros del MNPT informarán a las personas privadas de libertad y demás personas y/o instituciones relacionadas con la privación de libertad, sobre las características del trabajo a realizar, los alcances y limitaciones de las competencias del mecanismo, actuando siempre de manera correcta en todo momento”.

160. Por otra parte, el artículo 4 del referido Protocolo regula la confidencialidad, estableciendo que los datos personales de todas las personas que hayan entregado información al Mecanismo tendrán el carácter de información reservada, a menos que la entrega de dicha información sea autorizada por escrito. La disposición en cuestión extiende el alcance del principio de confidencialidad al trabajo desarrollado por el Mecanismo y de la planificación de las visitas.
161. A su vez, el artículo 6 del citado Protocolo realiza una categorización de las visitas que realiza el MNPT, destacando entre ellas las visitas de seguimiento, que tienen dentro de su propósito, entre otros, *“asegurar que las personas privadas de la libertad que colaboraron con el equipo no hayan sufrido represalias, además de examinar otros aspectos del lugar de privación de libertad”*, y las visitas coyunturales que tienen como objetivo verificar de forma inmediata los hechos suscitados en los lugares de privación de la libertad, por encontrarse en riesgo la integridad personal de personas privadas de libertad. El artículo 9 del mismo Protocolo, a su vez, versa respecto del desarrollo de las visitas, y vuelve a hacer referencia a la reserva de la información obtenida, cuando señala que *“[t]oda la información respecto a la identidad de las*

personas privadas de la libertad y/o del personal que labora en los lugares de privación de libertad, que entreguen datos respecto de posibles vulneraciones de derechos, será llevada con absoluta confidencialidad”.¹⁷²

162. En el caso de Argentina, la Ley N° 26.827, de 07 de enero de 2013, que establece el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes establece en su artículo 7, letra ñ) como una de las funciones del Mecanismo, “*comunicar a las autoridades nacionales o provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los magistrados y funcionarios judiciales que correspondan, la existencia de hechos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes denunciados o constatados por el Comité Nacional para la prevención de la Tortura o los Mecanismos Locales para la prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Solicitar la adopción de medidas especiales urgentes para el cese del maltrato y su Investigación y para la protección de las víctimas y/o de los denunciantes frente a las posibles represalias o perjuicios de cualquier tipo que pudiera afectarlos*”.
163. Asimismo, el artículo 44 de la referida ley, establece que las autoridades competentes deberán garantizar la investigación judicial o administrativa de la situación que haya sido denunciada. Por su parte, el artículo 45, establece que siempre se requerirá el consentimiento informado de la víctima para publicar sus datos personales, pauta que la disposición extiende a toda información confidencial a la que acceda el MNPT y que se propenderá al desarrollo conjunto con la víctima o su familia de estrategias.
164. Respecto de la protección de la víctima, el artículo 46 de esta ley, establece que aún cuando no se cuente con el consentimiento de la víctima, en caso de verificarse los supuestos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se deberán presentar todas las acciones que correspondan para asegurar integridad de la persona afectada.
165. Por otra parte, respecto del deber de confidencialidad, el artículo 47 de la ley *en comento*, establece que toda información recibida por la autoridad será reservada, salvo que exista autorización del afectado para hacerla pública o utilizarla. La ley establece, además, que las recomendaciones o el fundamento en el que se basen sus acciones deberá mantener en reserva la fuente de la información, y que los datos personales de las víctimas deberán ser reservados en caso de que su publicación pudiera ponerlas en riesgo.
166. En último término, el artículo 53 de la ley en cuestión, establece la prohibición de cualquier represalia, en relación con la denuncia de hechos que puedan configurar tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mientras que el artículo 54 de la misma ley establece el deber de protección del Estado argentino con los testigos que se encuentren expuestos a sufrir alguna represalia¹⁷³.
167. A diferencia de las experiencias expuestas en los párrafos anteriores, en el caso de Costa Rica, la Ley N° 9.204, que crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes no establece dentro de las facultades del MNPT, la posibilidad de iniciar acciones o la remisión de los antecedentes a

¹⁷² Defensoría del Pueblo de Ecuador, “Soporte Teórico del Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes del Ecuador”, Quito, 2016, p. 93 y ss.

¹⁷³ Argentina. Ley N°26.827, que establece el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

alguna institución por la denuncia de algún caso. Por el contrario, el artículo 8 de la Ley ya referida circunscribe la prohibición de sanciones a consecuencia de la entrega de información y la confidencialidad de la información recabada por el Mecanismo, sólo a las funciones establecidas en el artículo 5 de esta ley, las cuales son: (i) supervisar el trato que reciben las personas privadas de libertad con el fin de fortalecer su protección; (ii) hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad; y por último, (iii) realizar trabajo legislativo con el de adecuar de mejor forma la legislación a los estándares internacionales, para fortalecer la protección de las personas privadas de libertad.¹⁷⁴

168. En resumen, como se puede apreciar, la tensión existente entre el deber de confidencialidad y la protección de la persona privada de libertad que entrega información, con el deber de denunciar este tipo de hechos ilícitos, se encuentra resuelto desde la perspectiva de los estándares internacionales y las diversas experiencias que hemos descrito en los párrafos precedentes. Sea desde una perspectiva jurídica, desde una mirada ético profesional o político institucional, la gran mayoría los antecedentes levantados le dan prioridad y prevalencia a la protección de la persona privada de libertad que ha entregado información, respecto del deber denunciar el acontecer de este tipo de circunstancias.
169. En este sentido, se entiende que desde la perspectiva de la prevención de la tortura, el principio de no dañar permite aumentar los grados de confianza de las personas privadas de libertad con los MNPT, vigorizando la legitimidad de la actividad incipiente que estos Mecanismos están desarrollando. Por otra parte, ello refuerza la idea de que el diálogo como resolución de conflictos en temas tan complejos como la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos y Degradantes, constituye un camino necesario para la construcción de consensos y cambios culturales que se traduzcan en una mejor y mayor protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

V. CONCLUSIONES

170. Según se ha examinado, la revisión de la historia fidedigna de la ley, la legislación chilena, los estándares comparados de actuación de otros Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, y los estándares internacionales, permiten arribar a las siguientes conclusiones:
- (i) A efectos de determinar la existencia de un “riesgo vital” que gatille la obligación de denuncia de los miembros del Comité, debe tenerse presente la especial posición de garante del Estado respecto de las personas privadas de libertad, que le exige actuar oportunamente frente a amenazas a la vida. En consecuencia, dicho concepto debe ser interpretado flexible y razonablemente, sin exigir la certificación de un médico ni otro criterio de verificación, sino bastando con la constatación de un miembro del Comité,
 - (ii) La obligación de denuncia en casos de tortura no se encuentra limitada a aquellos actos de tortura según se encuentran definidos en la Convención contra la Tortura

¹⁷⁴ Costa Rica. Ley N°26.827, que crea el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos y Degradantes.

y/o el artículo 150A del Código Penal –en tanto ellos requieren la participación de un funcionario público–, sino que debe interpretarse de manera amplia, incluyendo también casos en que los actos de tortura hayan sido perpetrados por un privado, incluyendo otra persona privada de libertad.

- (iii) Finalmente, en lo relativo a la tensión que existe entre el deber de denunciar y el deber de confidencialidad y reserva que deben respetar los miembros del MNPT, los estándares revisados confirman que esta segunda obligación tiene prioridad, debiendo en consecuencia los miembros del Comité obtener el consentimiento de la persona afectada antes de revelar información a las autoridades –incluyendo mediante una denuncia– sobre la presunta comisión de actos que constituyan riesgo vital o torturas. Sin embargo, atendida la especial protección que se concede a los NNA, es posible que el Comité deba establecer protocolos de actuación específicos respecto de posibles actos de violencia cometidos contra NNA, de manera de examinar adecuadamente la relación entre el deber de confidencialidad y el interés superior del niño.